

الأزهر الشريف

كلية الشريعة والقانون

الفرقة الثانية

الفقه المقارن

اعداد : د عبدالله الأزهرى

(الوحدة الأولى)

❖ **المطلب الأول البيوع المنهي عنها إما لذاتها أو لصفة فيها**

أولاً: ما كان النهي وارداً لذاته:-

1- حكم بيع الخنزير:-

أجمعت الأمة على أن الخنزير محرم لا يجوز بيعه وذلك لقوله تعالى: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ " .

✚ خص الله اللحم من لحم الخنزير؛ لأن معظم الانتفاع متعلق به وليدل أيضاً على تحريم عينه زكي أو لم يزك وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف .

واختلف الفقهاء في شعر الخنزير على مذهبين:-

أبو حنيفة وابن القاسم من المالكية	ذهب الشافعية والحنابلة وأصبغ من المالكية
جواز بيع شعر الخنزير لأنه يجوز الانتفاع به في الخرازة وحجتهم أن المسلمين يقرون الأساكفة على استعماله من غير نكير ولأن الحاجة إليه ماسة . وقال ابن القاسم من المالكية: لا بأس ببيع شعر الخنزير خنزير الوحش وهو مثل صوف الميتة .	لا يجوز بيع شعر الخنزير ولا الانتفاع به في الخرز لأنه نجس . الخنزير ليس بحلال حيا ولا ميتا فلا يباع ولا شيء منه ولا يؤكل ثمنه ولا تجوز التجارة فيه والكلب أحل منه وأظهر وثمنه لا يحل وقد حرمه رسول الله ﷺ حين نهى عن ثمنه .

الراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول .

خنزير الماء:-

اختلف الفقهاء في خنزير الماء:-

الجمهور	مالك	أبو حنيفة
لا بأس بأكل شيء يكون في البحر والانتفاع به لقوله تعالى: ﴿أَحْلَلْ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلْغِيَارَةِ﴾ فكان على عمومهم في جميع حيوانه ومن ثم يجوز بيعه .	قال: أنتم تسمونه خنزيراً وقال ابن القاسم: أنا أتقيه ولا أحرمه .	كخنزير البر يحرم الانتفاع به وذلك لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَازِيرِ﴾

والراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لأن الخنزير إذا أطلق فإنه يتبادر إلي الفهم خنزير البر لا خنزير البحر .

2- حكم بيع الكلب:-

اختلف الفقهاء في جواز بيع الكلب على أربعة مذاهب:

المذهب الأول لا يجوز مطلقاً	المذهب الثاني يجوز في كلب الصيد فقط	المذهب الثالث يجوز في الكلب المأذون في إمساكه	المذهب الرابع يجوز مطلقاً
وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه الدليل: 1. روى عن ابن مسعود الأنصاري أنه ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وخُلوان الكاهن .	روى عن جابر أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد .	مثل الكلب المعلم (كلب الصيد) وكلب الماشية . واستدلوا بما استدل به أصحاب المذهب السابق	يجوز مطلقاً وثمنه حلال والقيمة على متلفه واجبة . الدليل: 1. أنه مال منتفع به حقيقة ومباح الانتفاع به شرعاً على

2. عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن الكلب خبيث وهو أخبث منه". 3. عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله عن ثمن الكلب وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملاً كَفَّهُ تراباً . 4. ولأنه حيوان منهى عن اقتنائه في غير حال الحاجة إليه فأشبهه الخنزير ولأنه حيوان يجب غسل الإناء من ولو غه فوجب أن يحرم ثمنه وقيمه قياساً على الخنزير .	"عن عبد الله بن عمرو أنه قضى في كلب الصيد أربعين درهماً وفي كلب الغنم شاة وفي كلب الزرع قَرَقاً" ولأنه حيوان يباح الانتفاع به ويصح نقل اليد فيه والوصية به .	الإطلاق لأن الانتفاع به من جهة الحراسة والاصطياد مطلق شرعاً في الأحوال كلها فكان محلاً للبيع. 2. لأنه حيوان يجوز الاصطياد به فجاز بيعه كالفهد والنمر . 3. ولأنه حيوان تجوز الوصية به فجاز بيعه كالماشية . ونوقش هذا الاستدلال: بأن القياس على الفهد بعله جواز الاصطياد ثم المعنى في الفهد طهارته حياً.
--	--	---

الراجع: أميل إلى ترجيح المذهب الثالث .

3- حكم بيع الميتة:-

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز بيع الميتة وذلك لقوله تعالى: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ " ولكن وقع الاختلاف بينهم في أجزاء الميتة كالجلد والصوف والشعر والوبر .

أولاً: الجلد:-

حكم الجلد قبل الدباغ

عامة العلماء	ابن شهاب الزهري والليث
لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ لأنه نجس	حيث أجاز بيع جلد الميتة وأن لم يديغ واستدلاً على ذلك بقوله تعالى: " وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ " حيث أباح الله الانتفاع بجلود الميتة بوجه عام سواء كانت مذكاة أو ميتة

- ولكن يعترض الآية عامة إلا أنها مخصصة بجلد الحيوان الحي بدليل قوله تعالى في آخرها " وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارُهَا وَأَشْعَارُهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى حِينٍ " أي إلى حين الموت فدل على أن الجلد المنتفع به هو ما كان من الحيوان المذكي فقط .

الترجيح: لا يخفى ما في قول الجمهور من وجاهه تجعله يستحق الترجيح عن غيره .

حكم جلد الميتة المدبوغ

جمهور الفقهاء:	بعض الفقهاء:
يجوز بيعه لأنه طاهر منتفع به فيكون مالا .	لا يجوز بيع جلد الميتة وهذا مبني على أنه لا يطهر بالدباغ وهو مردود لقوله "أيما إهاب ديبغ فقد طهر"

ثانياً: الصوف والوبر والشعر والعظم:-

- إذا كان قد جُرَّ من حيوان طاهر وهو حي فإنه طاهر بالإجماع .

- أما إذا كان الشعر والوبر والصوف من حيوان ميت فقد اختلف الفقهاء في حكم بيع هذه الأشياء من الميتة والانتفاع بها على مذهبين:-

المذهب الأول: يجوز الانتفاع بها وبيعها وبه قال الحنفية والمالكية .

المذهب الثاني: لا يجوز الانتفاع بها ولا بيعها وإليه ذهب الشافعية والحنابلة .

الأدلة والمناقشة

المالكية والأحناف

- 1- من الكتاب: " وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارُهَا وَأَشْعَارُهَا أَثْنَا وَمِئَةً إِلَى جِبِنٍ "

فقد أخبر الله عز وجل أنه جعل هذه الأشياء لنا ومن علينا بذلك من غير تفصيل بين الذكية منها فدل على تأكيد الإباحة .

مناقشة الدليل: الآية مجملة لأنه أباحها إلى حين فقد يحتمل ذلك إلى حين الموت .

الآية تقتضي التبعض لأنه سبحانه وتعالى قال: " وَمِنْ أَصْوَابِهَا " فدل هذا على أن منها ما يكون أثاثاً ومتاعاً ومنها ما لا يكون ذلك .
- 2- من السنة: 1. أم سلمة تقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء " .

دل على طهارة الشعر بعد الغسل والعين النجسة لا تطهر بالغسل فدل هذا على طهارة الشعر قبل الغسل .

الاعتراض على هذا الدليل: ضعيف لا يجوز الاستدلال به .
2. النبي ﷺ أتاه رجل فقال: يا رسول الله أصلي في الفراء؟ فقال: "أين الدباغ؟"

ونوقش: بأن قوله ﷺ: أين الدباغ؟ يعني لاستصلاح لبسها إذ لا يكون لبسها قبل الدباغ .

الجواب عن هذه المناقشة: تأويل بعيد يخرج الحديث عن معناه .
- 3- من المعقول: أن تحرم الميتة ليس لموتها فإن الموت موجود في السمك والجراد وهما حلالان لقوله: لما فيها من الرطوبات السيالة والدماء النجسة لانجمادها بالموت يظهر الجلد بالدباغ حتى يجوز بيعه لزوال الرطوبة عنه بالدبغ ولا رطوبة في هذه الأشياء فلا تكون نجسة .

الشافعية والحنابلة

- 1- من الكتاب: " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ "

والشعر والعظم من جملة الميتة بدليل أنه لو حلف أن لا يمس ميتة فمس شعرها أو عظمها يحنث .

الاعتراض على الاستدلال بهذا الدليل: اسم الميتة وإن كان ينطلق على الجملة إلا أنه إنما يرجع في الحقيقة إلى ما فيه حياة وهذه الأشياء لا حياة فيها فلا يتناولها التحريم .
- 2- من السنة: عن عبد الله بن عكيم قال: كتب إلينا رسول الله ﷺ: "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" .

دل هذا الحديث على عدم جواز الانتفاع من الميتة بشيء .

مناقشة الاستدلال بهذا الدليل: الإهاب اسم لغير المدبوغ لغة والمراد من العصب في الحديث أي حال الرطوبة .
- 3- من المعقول: هذه الأشياء حية وبها روح تموت بموت أصلها فتتجس بالموت والدليل على كونها حية: أن النماء من سمات الحياة والشعر ينمو في حال اتصاله بأصله وحياته يفقد هذا النماء إذا فصل عنه .

الاعتراض على هذا الدليل: وجود النماء في الشعر لا يوجب الحياة له .

الترجيح: ترجيح رأي الحنفية القائل بجواز الانتفاع بالشعر والصوف ونحوهما .

ثالثاً: بيع أنفحة الميتة وألبانها:-

أحمد الشافعي	مالك أبو حنيفة داود
لين الميتة وأنفحتها لا يجوز بيعه لعموم قوله " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ " فتحرم الميتة وكل أجزائها ومنها اللبن والأنفحة . ● ولأنه مائع في وعاء نجس فكان نجساً كما لو حلب في وعاء نجس . ● ولأنه لو أصاب الميتة بعد فصله عنها لكان نجساً فكذلك قبل فصله . الاعتراض على هذا الدليل: أن قياس تنجيس اللبن في الضرع على تنجيسه إذا حلب في وعاء نجس قياس فاسد لأن اللبن في الضرع	طاهرة يجوز بيعها . الأدلة: 1- من الكتاب: "وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ" وجه الدلالة: تدل الآية على طهارة لبن الميتة من وجهين: 1. ذكر كونه سائغاً للشاربين بوجه عام ولا فرق فيه بين الحية والميتة لأنه لا يموت ولا ينجس بالمجاورة . 2. أخبر الله أن اللبن يخرج من بين فرث ودم نجسان مع أنه طاهر فلم يتنجس بالمجاورة فكذلك بعد الموت . 2- من السنة: 1. أتى النبي ﷺ في غزوة الطائف بجبنة فجعلوا يقرعونها بالعصا فقال ﷺ "أين يصنع هذا" فقالوا بأرض فارس فقال

يكون في موضع الخلقة وهو لا ينجس ما جاوره بما حدث فيه خلقة وأما بعد الحلب فهو ينجس بفعل خارج عنه فينجس . عليه السلام اذكروا اسم اللع عليه وكلوا . وجه الدلالة من الحديث: - من المعلوم أن ذبائح المجوس ميتة وقد أباح عليه السلام أكلها مع العلم بأنها من صنعة أهل فارس وأنهم كانوا إذ ذاك مجوساً ولا ينعقد الجبن إلا بالأنفحة فثبت أن أنفحة الميتة طاهرة . - ما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهما _ أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو يعمل بالأنفحة وهي تؤخذ من صغار المعز فهو بمثابة اللبن وذبائحهم ميتة . الاعتراض على هذا الدليل: المجوس ما كانوا يتولون الذبح بأنفسهم وإنما كان جزاروهم من اليهود والنصارى وهما أهل الكتاب . الجواب على هذا الاعتراض: مجرد افتراض وأن سلمناه .	
--	--

الترجيح: ترجيح رأي الحنفية ومن معهم لقوة أدلتهم .

حكم بيع الزبل والرجيع والعذرة :

لا خلاف بين الفقهاء في أن زبل ما يؤكل لحمه مما لا يستخدم النجاسة في أكله كالحمام طاهر ويجوز بيعه .

ولكن وقع الاختلاف بين الفقهاء في الزبل النجس:

المالكية والشافعية والحنابلة:	أبو حنيفة:
لا يجوز بيعها وذلك لأنها نجسة فهو كالميتة .	يجوز وذلك للحاجة إليه فإن أهل القرى يتعاونونه لزرعهم فهو منتفع به لأنه يلقى في الأرض لاستكثار الربيع فكان مالا والمال محل للبيع .

ومذهب الأحناف هو الرأي الذي يترجح في نظري .

المطلب الثاني

ما كان النهي عن بيعه لأمر خارج عنه

بيع الطير في الهواء والسماك في الماء :-

أ - بيع الطير في الهواء:-

- لا خلاف في أنه لا يجوز بيع الطير في الهواء الذي لا يملك وهو الطير المرسل الذي لا يؤدي مأوى مملوك وذلك لعدم الملك ولعدم القدرة على التسليم .

- ولا يجوز بيع الطير الذي أمسكه ثم أرسله لعدم القدرة على التسليم .

➤ **وأما الطير الذي يملك كالحمام**

ذهب عامة أهل العلم	بعض الحنفية	الشافعية والقاضي من الحنابلة
لا يجوز بيعه في الهواء لعدم القدرة على تسليمه في الحال .	جواز بيعه لأنه يقدر على تسليمه بعد عودته وذلك قياساً على بيع الغائب . واعترض على هذا أن الغائب يستطيع المالك استحضاره وأما الطير في الهواء لا يستطيع استحضاره إلا أن يعود بنفسه .	أنه إذا لم يمكن أخذه إلا بمشقة وتعب لم يجز بيعه . واعترض عليهم البعيد يلزم في احضاره المشقة والكلفة ومه ذلك هو جائز . أجيب عنه البعيد تعلم الكلفة التي يحتاج إليها .

ب - بيع السمك في الماء:-

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز بيع السمك في البحر أو في النهر وذلك لعدم الملك فيه وعدم القدرة على التسليم .

- وأما بيع السمك في الآجام فقد اختلف فيه الفقهاء على النحو التالي:

عمر بن الخطاب وابن مسعود	الحسن والنخعي أبو حنيفة ومالك والشافعي	عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى
لا يجوز	مكروه لما روي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود أنهما قال لا تباعوا السمك في الماء فإنه غرر وقد نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر . فإن وقع جاز بثلاثة شروط: 1. مملوكاً للبائع . 2. أن يكون الماء رقيقاً يسمح بمشاهدة السمك ومعرفة . 3. أن يمكن اصطياذه فيجوز لأنه مملوك معلوم يمكن تسليمه أما إذا اختلف شرط من هذه الشروط لم يجز بيعه .	يجوز لأنه يقدر على تسليمه ظاهراً .

والرأى: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك لأنه غرر ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا بعد اصطياذه ولأنه مجهول .

حكم بيع المغصوب والآبق:-

- لا يجوز بيع المغصوب والآبق لعدم القدرة على التسليم وكذلك الجمل الشارد فإن باعه لغاصبه أو لقادر على أخذه منه جاز لعدم الغرر فيه ولا مكان قبضه .

- ويجوز البيع لمن ظن أنه قادر على أخذه من غاصبه أو ظن أنه يستطيع رد الشارد فإن لم يستطع أخذه أو رده ثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء لأن العقد صح لكونه مظنون القدرة على قبضه وثبت له الفسخ للعجز .

بيع اللبن في الضرع:

الجمهور	الرأى:	مالك
لا يجوز بيع اللبن في الضرع لما يأتي: 1. أنه غرر لجواز أن يكون الضرع منتفخاً يظنه لبناً وقد نهى النبي عن بيع الغرر: " نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصة وبيع الغرر". 2. النزاع في كيفية الحلب فإن المشتري يستقصي في الحلب والبائع يطالبه بأن يترك داعية اللبن . 3. أن اللبن يزداد ساعة فساعة والبيع لم يتناول الزيادة الحادثة بعد العقد وقبل الحلب لعدمها عند البيع فيختلط المبيع بغيره واختلاط المبيع بغيره من ملك البائع على وجه لا يمكن فصله عنه ولا تمييزه منه مبطل للبيع . 4. ولأنه مجهول القدر غير مشاهد ولا معلوم فلم يصح بيعه .	يجوز بيع اللبن في الضرع أياماً إذا عرف حلابها لسقى الصبي قياساً على جواز بيع لبن الظئر ولأن لما جاز بيعه مع الشاة جاز بيعه مفرداً عنها .	

2- بيع النوى في التمر والبيض في الدجاج:

لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز بيع النوى في التمر وكذلك البيض في الدجاج وذلك للجهل به .

3- بيع الصوف على الظهر:

الجمهور الفقهاء	مالك وأبو يوسف من الحنفية والحنابلة
لا يجوز بيعه لأنه من أوصاف الحيوان فكان كالوصف من الذات فلم يجز إفراذه بالعقد كسائر أعضاء الحيوان ولما روي عن ابن عباس نهى النبي ﷺ أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع . مناقشة الاستدلال بهذا الدليل: نوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه مرسل	في غير المشهور: يجوز بيع الصوف على الظهر لأنه معلوم يمكن تسليمه بشرط جزه في الحال لأنه معلوم يمكن تسليمه فجاز بيعه كالرطبة .

	الجواب عن هذه المناقشة: أوجب المرسل حجة كالمرفوع . 2- الصوف في حالة نمو مستمر فيختلط الموجود عند العقد بالحادث على وجه لا يمكن تمييز ملك المشتري من ملك البائع . مناقشة الاستدلال بهذا الدليل: يمكن أن يدفع باشتراط جزه في الحال أو بعد وقت يسير لا ينمو فيه الشعر نمواً يؤثر في قيمته .
--	---

الراجح: أنه إذا كان بشرط الجز في الحال فهو جائز وإلا فلا لما فيه من التيسير على الناس .

بيع الملامسة والمناذة:

هذه البيوع كانت في الجاهلية وهي أن يتراوض الرجلان على سلعة فإذا لمس المشتري أو نبذها إليه البائع أو وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع فالأول بيع الملامسة والثاني المناذة والثالث إلقاء الحجر .

والمناذة: أن يقول المشتري للبائع أي ثوب نبذته إلي فقد اشتريته بكذا .

والملامسة: أن يبيعه شيئاً ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع وفسره الشافعي: من أن يأت بالرجل بثوبه مطوياً أو في سقط أو تكون ظلمة فيقول: أبيعك هذا الثوب على أن تلمسه بيدك ولا خيار لك إذا أبصرته وعرفت طول وعرضه .

وبيع الحصاة: أن يقول أرمي هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك .

وهذه البيوع منهي عنها لا يجوز منها شيء

أ. لما روي عن أبي هريرة " أن رسول الله ﷺ نهى عن الملامسة والمناذة
ب. ولأن فيها تعليقاً بالخطر والبيع عن عقود التمليك وعقود التمليك لا تحتمل التعليق بالخطر فهذا البيع منهي عنه ولما فيه من الغرر .

بيع الملاقيح والمضامين:

الملاقيح : ما في البطون وهي الأجنة .

المضامين : ما في أصلاب الفحول من الماء .

كان في الجاهلية يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضربه الفحل في عامة فجاء الإسلام ومنعه وذلك

أ. لجهالته فإنه لا تعلم صفته ولا حياته ولأنه غير مقدور على تسليمه .

ب. ولما "أن النبي نهى عن بيع الملاقيح والمضامين" وهذا البيع فيه غرر وهذا مما أجمع عليه الفقهاء .

بيع النجش

النجش لغة: الاثارة للشيء .	وفي اصطلاح الفقهاء: أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو غير راغب فيها وإنما ليغر غيره .
----------------------------	--

– والناجش قد يكون هو البيع إذا أنه قد يخبر بأنه اشترى السلعة بثمن أعلى من ثمنها الحقيقي وقد يكون أجنبياً بالمواطأة مع البائع أو بدونها .

 **صورته:** يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع فيمن يزيد فيزيد في ثمنها وهو لا يرغب في ابتياعها ليقتدي به الراغب فيزيد لزيادته ظناً منه أن تلك الزيادة لرخص السلعة اغترار به .

حكم النجش: النجش حرام وخداع

وقد اختلف الفقهاء في حكم البيع إذا تم على هذا النحو على مذاهب:

طائفة من أهل الحديث	المالكية وابن حزم	الحنفية والأصح عند الشافعية
البيع فاسد لا يفيد الملك عمر بن عمر عبد العزيز بعث عبيد بن مسلم يبيع السبي فلما فرغ أتى عمر فقال له: أن البيع كان كاسداً	يثبت الخيار للمشتري وذلك لأن النجش يعتبر عيب من العيوب فإذا أطلع عليه	البيع صحيح مع الإثم ولا خيار للمشتري أ. وذلك لأن المشتري وإن اقتدى بالناجش إلا أنه قد زاد في السعر باختياره

ب. ولأن النهي الوارد في بيع النجش إنما هو للناجش لا للعائد فلم يؤثر في عقد البيع .	المشتري ثبت له الخيار قياساً على المصراة .	لولا أنني كنت أزيد عليهم وانفقه فقال عمر هذا نجش لا يحل ابعث منادياً ينادي أن البيع مردود وأن النجش لا يحل فلولا أن البيع فاسد لما رده عمر بن عبد العزيز ولأثبت لهم الخيار .
--	--	--

الترجيح: رأي من يقول بثبوت الخيار للمشتري .

🌈 بيع الرجل على بيع أخيه

اختلف الفقهاء في تحديد المراد ببيعه على بيع أخيه على مذهبين:

أبو حنيفة ومالك	الشافعية والحنابلة
طلب رجل من آخر شراء سلعة منه فيتفقان على الثمن ويركن إليه البائع ولم يبق بينهما إلا اختيار النقود أو اشتراط العيوب أو البراءة منها فيأتي رجل آخر فيقول : أنا أبيعك أفضل منها بأقل من سعرها أو نحوها أو يقول البائع أنا أشتريها منك بأعلى من هذا السعر .	إلى أن وقت التحريم أن يأتي إلى البائع والمشتري في زمن الخيار ليعرض عليه ببيعه بأقل من هذا السعر أو شراء السلعة من البائع بأعلى من هذا السعر وهو منهي عنه قال عليه السلام : " لا يبيع بعضكم على بيع بعض " .

◀ **حكم البيع إذا حدث:** اختلف الفقهاء فيه على مذهبين

جمهور الفقهاء البيع صحيح	داود الظاهري وأحمد في رواية البيع فاسد
أولاً: لأن النهي الوارد عنه إنما هو لأمر خارج عن البيع وهو الإيحاء والإضرار فلا يفسد البيع . ثانياً: النهي الوارد في الحديث إنما هو محمول على الكراهة وذلك لما يوقع من الفرقة بين المسلمين .	لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه والنهي يقتضي الفساد .

والراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

بيع الثمار منفردة عن الأصول:

أولاً: بيع الثمار قبل أن تخلق .

ذهب معظم العلماء إلى أنه لا يجوز بيع الثمار منفردة عن أصولها وذلك للنهي عن بيع ما لم يخلق روي عن النبي أنه نهى عن بيع السينين وعن بي المعائمة وهي بيع الشجر أعواماً وهذا منه إلا ما روي عن عمر أنهما كانا يجيزان بيع الثمار سينين .

ثانياً: بيع الثمار بعد أن تخلق .

لا يخلو بيع الثمار منفردة عن أصولها بعد أن تخلق من أن يكون ذلك قبل بدو صلاحها

أ - بيع الثمار قبل بدو صلاحها

بيع الثمار قبل بدو صلاحها ر يخلو من أن يكون ذلم مطلقاً أي بدون شرط أو بشرط تيقيتها أو بشرط القمع .

1. بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط القطع

عامة الفقهاء الجواز	الثوري وابن أبي ليلى والظاهرية عدم جواز
أ. لأن المنع إنما كان خوفاً من تلف الثمرة وحدوث العاهة	أ. للنهي الوارد عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فهو على

عليها قبل أخذها روي عن أنس أن النبي نهى عن بيع الثمار حتى تزهو قال: "أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه" وهذا مأمون فيما يقطع فصيح ببيعته كما لو بدأ صلاحه . واشترط قطعها يؤمن معه عطبها وحدوث العاهة بها صح البيع .	عمومه ب. ولأن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع يجعل الثمرة غير منتفع بها فلم يجز .
--	---

٢. بيع الثمار قبل بدو الصلاح بشرط التبقية:

لا خلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط تبقيتها على أصولها حتى يبدو صلاحها لأن النبي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع والنهي يقتضي فساد المنهي عنه .

وهنا خمسة أحاديث تمنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح وألفاظها وإن كانت مختلفة فمعانيها متفقة .

3. بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقاً:

المالكية والشافعية والحنابلة : لا يجوز	الحنفية يجوز
أن النبي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها وأن هذا النهي يتناول البيع مطلقاً والبيع بشرط التبقية . - والنهي عند الجمهور إنما هو لخوف أن يصيب الثمرة جائحة لأنها معرضة قبل بدو صلاحها لذلك غالباً . ° ولأن إطلاق العقد يقتضي التبقية والترك لأن العرف في القبض يجري مجرى الشرط .	1. عن النبي قال من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع . فقالوا: أنه لما جاز أن يشترطها المبتاع جاز بيعها مفردة لأن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال فهو يؤمر بالقطع سواء اشترطوا أو أطلق . فيحمل إطلاق العقد على القطع ليصح ولا يحمل على التبقية ليفسد .

ويرجع ذلك الخلاف في هذا بين الجمهور والحنفية إلى أن أطلق العقد هل يقتضي القطع أم التبقية فالجمهور على أن الإطلاق يقتضي التبقية والحنفية على أن الإطلاق يقتضي القطع .

ثانياً: بيع الثمار منفردة عن أصولها بعد بدو الصلاح:

إذا كانت بشرط التبقية:

الجمهور يجوز	الحنفية لا يجوز
- أنه عليه السلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها فمفهومه إباحة بيعها حتى يبدو صلاحها . - لأن النبي نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتأمين العاهة . فتعليقه بأمن العاهة يدل على التبقية لأن ما يقطع في الحال لا يخاف عليه العاهة . - ولأن النهي إنما هو للخروج على الثمرة من الجائحة وبعد بدو الصلاح قد أمنت الجائحة .	لأن ملك المشري مشغول بملك البائع فلا بد من زوال الشغل بعد العقد فإن شرط التبقية فيكون قد اشترط الانتفاع بملك البائع على درجة لا يقتضيها العقد فلم يجز .

الراجع: جمهور الفقهاء .

(الوحدة الثانية)

المبحث الأول: نشأة الاحتكار

الفرع الأول:

(أ) الاحتكار في اللغة: الجمع والإمساك

والاحتكار هو: حبس الطعام انتظار غلانه

(ب) الاحتكار شرعاً:-

الحنفية:	المالكية:	الشافعية:	الحنابلة:
حبس الأقوات تربصاً للغلاء .	هو الادخار للمبيع وطلب الربح بتقلب السواق .	ههو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه .	شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام وحبسه عنهم بقصد إغلائه عليهم .

محتركات التعريفات السابقة:

1- حصرت الاحتكار في مجال الأقوات فقط .

2- بينت أن الاحتكار حبس السلعة تربصاً للغلاء .

3- حصرت الاحتكار في حالة الشراء في الأزمان فقط .

الفرع الثاني: موقف الإسلام من الاحتكار ودليله

حرم الإسلام الاحتكار

الأدلة:

1- من الكتاب: {ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم نذقه من عذاب أليم}

وجه الدلالة:

هذه الآية تدل بعمومها على تحريم الظلم والاحتكار نوع من أنواع الظلم

- أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه"

2- من السنة:

1. قال (صلى الله عليه وسلم): "من احتكر فهو خاطئ، فقيل لسعيد بن المسيب: فإنك تحتكر قال سعيد: إن معمرأ الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر"

وجه الدلالة: هذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار .

2. قال (صلى الله عليه وسلم): "من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ"

3. "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس"

وجه الدلالة من هذه الأحاديث: ظاهر الأحاديث يدل على أن الاحتكار محرم

حديث الحاكم قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) برجل بالسوق يبيع طعامه بسعر هو أرخص من سعر السوق فقال: "تبيع في سوقنا بسعر هو أرخص من سعرنا؟" قال: "نعم قال: "أبشر فإن الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله والمحتكر في سوقنا كالملاح في كتاب الله"

- "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"

ثالثاً: من الآثار:

- 1- ما روي عن عثمان بن عفان أنه كان ينهي عن الحكرة .
- 2- عن علي بن أبي طالب قال: من احتكر الطعام أربعين يوماً قسا قلبه " .
- 3- عن عبد الرحمن بن قيس قال: قال حبيش: أحرق لي علي بن أبي طالب ببادر بالسواد كنت أحتكرها لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة " .
- 4- وروي عن عمر بن الخطاب - أيضاً - أنه قال: "من جاء أرضنا بسلعة فليبيعها كما أراد وهو ضيفي حتى يخرج وهو أسوتنا ولا يبيع في سوقنا محتكر " .
- 5- روي عن علي بن أبي طالب أنه مر بشط الفرات فإذا كدس طعام لرجل من التجار حبسه ليغلي به على الناس فأمر به فأحرق " .

رابعاً: من المعقول:

الاحتكار فيه تضيق على الناس في أرزاقهم وأقواتهم وسبل معاشهم وظلم لهم بمنعهم من الحصول على ما يحتاجونه دون متاعب ومصاعب وفيه استغلال بشع لظروف الإنسان ولما كانت مثل هذه الأفعال تؤدي إلى إلحاق الضرر بالناس والعباد فإن الأصول المعتمدة في التشريع الإسلامي أن الحرمة تدور في الضرر فإذا وجد ضرر وجد حرمة فإن الاحتكار حرام لتوافر علة الضرر فيه .

المبحث الثاني: شروط الاحتكار

من المتفق عليه بين الفقهاء أن الاحتكار ليس مطلق الحبس فقط بل قد يحبس الإنسان يحبس الإنسان قوته وقوت عياله لمدة من الزمن سنة أو أكثر ولا يعد هذا من قبيل الاحتكار .

وبناءً على ما سبق فإن الاحتكار المحرم هو ما توافرت فيه شروط معينة كما وردت في كتب الفقهاء وهي:

الأول: أن يكون الشيء المحتكر من الأقوات للآدمي والبهائم على الأصح عند الفقهاء لقوله (صلى الله عليه وسلم) "لا يحتكر إلا خاطئ" وحديث "المحتكر ملعون" .

الثاني: أن يكون تملكه للسلعة بطريق الشراء من السوق بخلاف الجالب للسلعة من الخارج أو من ضيعته استدلالاً بقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"

– أما بعض المالكية والمنقول عن أبي يوسف من الحنفية فذهبوا إلى أن: العبرة إنما هي باحتباس السلع بحيث يضر بالعامّة سواء تملكها بطريق الشراء أو الجلب أو كان ادخاراً .

الثالث: أن يكون الشراء وقت الغلاء للتجارة انتظاراً لزيادة الغلاء أكثر .

رابعاً: تقدير الوقت الذي يعد فيه هذا العمل عملاً احتكاريّاً:

اختلف الفقهاء في الوقت بناء على الحديث المروي "من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله تعالى منه" .

واختلاف الفقهاء حول الحديث في: هل الوقت الوارد في هذا الحديث شرطاً من شروط الاحتكار أم لا؟ على أقوال:

أقل مدة الاحتكار هي أربعين يوماً لظاهر الحديث .	أقل مدة الاحتكار هي شهر لأن ما دونه عجل وتسرع .	ليس بالمدة سواء طالّت و قصرت لأن التقيد الوارد في الحديث لا يراد به التحديد وإنما المراد زجر المحتكر عن احتكاره الذي ينفع به نفسه ويضر غيره .	المحتكر يكون أثماً ديانة بنفس الاحتكار طالّت المدة أم قصرت وأن بيان المدة إنما هو لبيان ما يتعلق بها من أحكام الدنيا كإجبار المحتكر على بيع ما عنده دفعاً للضرر ونحو ذلك .
---	---	---	--

ثالثاً: الحكمة من تحريم الاحتكار وحكمه:

لما له من أضرار اجتماعية واقتصادية لعي العباد وهي:

- (1) إلحاق الضرر على المستهلك والتضييق على الناس في أرزاقهم ومعيشتهم .
- (2) يعتبر الاحتكار من قبيل أكل أموال الناس بالباطل .
- (3) إفساد المعاملات التجارية في الأسواق واحتقانها بين التجار .
- (4) من نتائج الاحتكار وحكمة تحريمه أيضاً تعميق الفوارق بين الفقراء والأغنياء .
- (5) يؤدي الاحتكار بالمحتاجين إلى السرقة والقتل وغيرهما من الجرائم .
- (6) أنه يؤدي إلى قتل روح المنافسة الشريفة بين التجار والتي تؤدي إلى الإتقان والتفوق في جميع المجالات .
- (7) يترتب على الاحتكار العديد من الأمراض المجتمعية كالبطالة والتضخم والكساد والرشوة والمحسوبية والنفاق والسرقة والغش ...

المبحث الثالث: ما يحرم فيه الاحتكار

الحنابلة	أبو يوسف والمالكية	الحنفية والشافعية
الحنابلة وابن المبارك وابن المسيب: أن الاحتكار لا يكون إلا في أقوات الأدميين فقط وبناء على ذلك قولهم لا يحرم الاحتكار في الزبيب والعسل ونحوهما من الثياب والحلوى والزيت وأعلاف البهائم . <u>دليلهم</u>: ما روي عن الأثرم أنه قال: "سمعت أبا عبد الله يسأل عن أي شيء الاحتكار؟ قال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره" .	الاحتكار يكون في أقوات الأدميين والبهائم وغيرها في كل ما يحتاجه الناس ويكون في حكره عنهم ضرر لهم . <u>واستدلوا على قولهم</u> <u>1- من السنة</u>: 1. لا يحتكر إلا خاطئ . 2. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليه مكان حقاً على الله أن يعقده بعظم من النار يوم القيامة . 3. من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ . <u>وجه الدلالة من هذه الأحاديث</u>: ظاهر الأحاديث كلها أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الأدمي والدواب وغيره . <u>2- من المعقول</u>: 1. أن التنصيص على الطعام في بعض الروايات لا يكون بالضرورة مقتضياً لتخصيص لأن ذلك من تنصيص على بعض أفراد العام . 2. العلة في الاحتكار هي الإضرار بالمسلمين أو العباد ككل فهذا يشمل كل ما يتضررون فيه باحتكاره . 3. تخصيص الجمهور الاحتكار بالقوتين إنما هو لحكمة المناسبة للتحريم وهي دفع الضرر عن عامة الناس.	أقوات الأدميين والبهائم اعتماداً على الضرر الغالب إنما يكون في حبسها مما يؤدي إلى الضرر لهما . <u>دليلهم</u>: "لا يحتكر إلا خاطئ" <u>وجه الدلالة</u>: هذا الدليل عام في الاحتكار إلا أنه أراد به الخصوص بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: "من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذام" <u>يرد على هذا</u>: ظاهر الأحاديث يحرم الاحتكار من غير فرق بين قوت الأدي والدواب وبين غيره . <u>ويجاب عن ذلك</u>: المقرر في قواعد الأصول أن المطلق يحمل على المقيد والعام يحمل على الخاص .

القول المختار: المذهب الثاني لأن العلة هي ما إذا كان هناك ضرر بالمسلمين فيحرم الاحتكار على الوجه الذي يضر بهم .

المبحث الرابع: الحكم الشرعي للاحتكار

يتفق الفقهاء على أن الاحتكار من أنواع الظلم الذي ينزل على الناس من قبل أفراد لا تعرف الله .

ومن هنا فإن الفقهاء متفقون على حرمة ومنهم من خالف ذلك وقال بأنه مكروه كراهة تحريم .

للفقهاء في حكم الاحتكار قولين:

بعض الحنفية وبعض الشافعية	الجمهور
الاحتكار مكروه كراهة تحريمية . <u>الأدلة</u>: <u>1- من السنة</u>: استدلوا بنفس أحاديث الرأي الأول: - لا يحتكر إلا خاطئ . - من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس . <u>2- من المعقول</u>: ● يكره الاحتكار في أقوات الأدمي والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله . ● أن البيع تعلق به حق العامة من الناس والامتناع عن البيع إبطال حقهم وتضييق الأمر عليهم فيكره كما يكره تلقي الركبان إذا أضر بأهل البلد .	الاحتكار محرم وليس مكروهاً . <u>الأدلة</u>: <u>1- من الكتاب</u>: " ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم " صلى الله عليه وسلم: " احتكار الطعام في الحرام - أي: الحرم - إلحاد فيه " . <u>2- من السنة</u>: 1. المحتكر ملعون والجالب مرزوق . 2. من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه . <u>وجه الدلالة</u>: 1. رسول الله صلى الله عليه وسلم توعد المحتكر باللعن واللعن هذا لا يكون إلا عن مباشرة حرام . 2. وعيده بالبراءة منه لا يلحق الإنسان إلا بارتكاب محرم فدل ذلك على أن الاحتكار من أنواع الظلم المحرم . 3. من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس .

	3- من الآثار: 1. عن عمر بن الخطاب أنه قال لا حكرة في سوقنا . 2. عن علي أنه أحرق طعاماً محتكراً بالنار . 3. وعن عثمان أنه كان ينهى عن الحكرة . 4- من المعقول: 1. الاحتكار فيه تضيق على الناس في أرزاقهم وأقواتهم . 2. إهدار حرية التجارة والصناعة . 3. من الأصول المعتمدة أن الحرمة تدور مع الضرر فإن الاحتكار حرام لتوافر علة الضرر فيه . 4. الاحتكار من باب الظلم لأن ما يبيع في المصر فقد تعلق به حق العامة فإذا امتنع المشتري عن بيعه عند شدة حاجتهم إليه فقد منعهم حقهم ومنع الحق عن المستحق ظلم وإنه حرام .
--	---

الرأي الراجح: ليس في هذه المسألة رأياً راجحاً حيث إنهما رأيان متفقان على تحريم الاحتكار ولكن كلاً بطريقته حيث إن الحرمة عند الجمهور تساوي الكراهة التحريمية عند الحنفية .

المبحث الخامس: وسائل منع الاحتكار ومضاره

الفرع الأول وسائل منع الاحتكار

اختلف الفقهاء في وسائل منع الاحتكار على قولين:

للمشافعية ورأي للحنفية وللمالكية وللحنابلة	لجمهور الفقهاء
ليس لولي الأمر الأمر بالتسعير في الأقوات ولا إكراههم على بيعها ولكن يجوز عندهم لغير ولي الأمر إجبارهم على البيع . 1. روي عن أنس قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال الناس: يارسول الله غلا السعر فسر لنا فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال" <u>وجه الدلالة من الحديث:</u> الأول: أنه (صلى الله عليه وسلم) لم يسعر وقد سأله ذلك ولو جاز لأجابهم إليه . الثاني: أنه (صلى الله عليه وسلم) علله بأنه مظلمة والظلم حرام . ثانياً: من المعقول: أن بيع الإمام لأمتعة الناس بغير رضاهم فهو على ضربين: الأول: أنه يكره عليه بيعها عليهم ولا يمكنهم تركها ويعتبر البيع باطل . <u>واستدلوا لذلك بما يأتي:</u> 1- الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه لأنه عقد مكره لا يجوز لأن الثمن حق العاقد فإليه تقديره . إن أكرهه غير السلطان فبيعه جائز لأن الإكراه من غير السلطان قادر دفعه ممكن من السلطان . إكراه السلطان للناس على بيع أمتعتهم مختارين من غير إكراه لكنهم كارهين للسعر فالبيع جائز غير أننا نكره الابتياح منهم إلا إذا علم طيب نفوسهم به	حق ولي الأمر أمر المحتكر على بيع ما احتكره فإذا لم يمثل أجبر على البيع وتسعيرها عليه 1- امتناع المحتكر عن بيع الطعام أو غيره اجتمع فيه ضرران أحدهما ضرر عام والآخر ضرر خاص فيقدم الضرر العام على الخاص . 2- إجبار المحتكر على البيع أمر جائز لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 3- للإمام بيع طعامه من غير رضاه إذا خاف هلاك أهل المصر ومن اضطر إلى مال الغير في مخمصة كان له أن يتناوله بالضمان . 4- يؤمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله فإن لم يفعل ورفع للإمام مرة أخرى وهو مصر على الاحتكار للإمام أن يعظه ويهدده فإن لم يفعل ورفع إليه مرة ثالثة يجبسه ويعزره زجراً له عن سوء صنعه . 5- إذا تعدى في القيمة تعدياً فاحشاً وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة أهل الرأي والبصر بالسوق .

والرأي الذي أراه راجحاً هو القول الأول .

الفرع الثاني:

مضار الاحتكار

للاحتكار مضار كثيرة نجلها فيما يلي:

(1) أنه دليل على دناءة النفس للمحتكرين وسوء خلقهم واتصافهم بالخصال الذميمة .

- (2) استحقاق المحتكرين للوعيد الذي توعدهم به رسولنا الكريم .
- (3) الاحتكار يورث الضغينة والبعد عن الناس والبعد عن الله .
- (4) الاحتكار هذا يسبب الاضطراب وعدم الاستقرار بين أفراد الشعب .
- (5) الاحتكار نوع من أنواع حب النفس المقيت والمزري .
- (6) الاحتكار يناقض الإيثار الذي هو جوهر العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم .
- (7) الاحتكار يؤدي إلى إفساد العلاقة بين أفراد المجتمع .

(الوحدة الثالثة)

المبحث الأول: مفهوم التسعير

معناه في اللغة: تقدير السعر

معناه في الاصطلاح:

الحنفية	المالكية:	الشافعية:	الشوكاني
"التسعير حجر معنى لأنه منع عن البيع بزيادة فاحشة"	"تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرأ كبيراً للمبيع بدرهم معلوم"	"أن يأمر الوالي السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا"	"هو أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمراً أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة"

التعريف المختار: تعريف الشوكاني لأسباب

أولاً: أن تقدير الثمن لابد وأن يكون ممن يملك سلطة التقدير .

ثانياً: تقدير السلع يجب أن يكون تقديراً عادلاً .

ثالثاً: تقدير السلع يجب أن يكون ملزماً لجميع الناس .

المبحث الثاني: حكم التسعير

البعض	جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة
جواز التسعير يجوز التسعير	الأصل في التسعير الحرمة خاصة إذا كان أهل السوق يقومون بما أوجب الله عليهم
1. "يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ"	1. يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ"
وجه الدلالة: بيع السلعة بزيادة خاصة في القيمة مع اضطراب الناس إليها أكل لأموال الناس بالباطل فالتجارة المشروعة لم تكن غصباً للحقوق واستغلالاً للحاجة .	وجه الدلالة: فإذا ألزم البائع بسعر محدد فقد انتفى هذا التراضي وكان البيع مشوباً بالإكراه والمشتري قد أكل مال البائع بالباطل .
2. قال رسول الله "من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد فَوَرَمَ العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق"	2. قال رسول الله (ﷺ): "إنما البيع عن تراضٍ"
وجه الدلالة: قوله - عليه السلام -: (قوم عليه قيمة العدل) فالتقويم هنا: هو التسعير .	وجه الدلالة: فقد حصر الحديث قيام البيع بقيام الرضا ومفهومه أنه لا يقوم البيع بانعدام الرضا فإذا أكره على البيع بثمن معين انعدم الرضا الذي هو شرط لصحة البيع .
3. أن رسول الله قال: "لا يبيع حاضر لبادٍ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"	ونوقش هذا الاستدلال بوجهين: الأول: ليس في التسعير إكراه على بيع الإنسان ماله . الثاني: ليس الإكراه على البيع باطلاً كله

3. عن أنس قال: غلا السعر بالمدينة على عهد النبي (ﷺ) فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله "إن الله هو المسعر القابض الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال"

وجه الدلالة: أن النبي لم يسعر رغم طلب الصحابة ولو جاز التسعير لأجاب الرسول أصحابه إلى ما طلبوه منه ثم إن الرسول علل عدم التسعير لكونه مظلماً والظلم حرام ونوقش هذا بأمرين:

الأول: الحديث ليس فيه نهي صريح منه .

ويجاب عن ذلك: بأن إخبار النبي بأنه يريد أن يلقى الله تعالى وليس لأحد عنده مظلومه يدل على أن التسعير ظلم محرم .

الثاني: امتناع النبي عن التسعير هنا قضية معينة وليس لفظاً عاماً .

ويجاب عن ذلك: بأنه لو كانت قضية معينة لبين النبي ذلك في حينه .

ثالثاً: المعقول: فمن وجوه:

1- إن التسعير يسبب الغلاء لأن التجار إذا علموا بتحديد السعر فإنهم لا يقومون بشراء السلع التي يحتاج الناس إليها مما يترتب عليه الاتجار في السوق السوداء .

2- الناس لهم حرية التصرف في أموالهم التي يمتلكونها والتسعير حجر عليهم وهو أمر لا يجوز .

3- الثمن حق المتعاقدين فلهما تقديره والتراضي عليه دون إلزام من أحد .

ونوقش هذا: الاستدلال بهذا المعقول لا يصلح دليلاً إذا أن الحاكم مأمور برعاية مصالح الأمة وليس نظره في مصلحة المشتري بأولى من نظره في مصلحة البائع .

وجه الدلالة: نهى الحاضر العالم بالسعر أن يبيع للبادي الجالب للسلعة الجاهل بالسعر لأن هذا يؤدي إلى غلاء الأسعار .

4. أن النبي قال: "لا ضرر ولا ضرار من ضرار الله ومن شاق شق الله عليه" .

وجه الدلالة: كانت منفعة أحد من الناس تلحق الضرر بآخرين حرم ذلك النفع فغلاء الأسعار يضر بالمشتري والبيع بأقل من ثمن المثل يضر بالبائع والتسعير: هو البيع بثمن المثل وهو عدل . من الأثر:

أن عمر بن الخطاب مر على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب: "إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا" .

وجه الدلالة: الأثر يدل على التسعير لأن حاطب كان يبيع في السوق دون سعر الناس فأمره عمر أن يلحق بسعر الناس أو يقوم من السوق حتى لا يتسبب في خسارة عامة أهل السوق .

ونوقش هذا الأثر بـ:

الوجه الأول: هذا الأثر ليس فيه تسعير .

الوجه الثاني: وعلى فرض أن الأثر يدل على التسعير فقد روى أن عمر رجع عن ذلك .

من المعقول:

1- في التسعير صيانة لحقوق المسلمين من الضياع .

2. للإمام أن يلزم المتحكر ببيع سلعة بسعر معين فكذلك له أن يضع تسعيرة محددة لكل سلعة من البداية .

ونوقش ذلك: إجبار المحتكر على بيع سلعته بثمن معين إنما كان على وجه العقوبة والتسعير من البداية يجب ألا يكون على وجه العقوبة .

سبب الخلاف بين الفقهاء:

سبب اختلاف الفقهاء اختلافهم في مفهوم الآثار الواردة في ذلك .

الرأي الراجح: من التسعير ما هو ظلم محرم ومنه ما هو عدل جائز فأباحته مطلقاً لا تجوز ومنعه مطلقاً لا يجوز .

فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه كالتسعير الجبري المعروف في أيامنا هذه فهو حرام .

إذا تضمن العدل بين الناس وإكراه الباعة على البيع بثمن المثل عند الجشع والاحتكار فهو واجب لأنه إلزام بالعدل الذي أمر الله تعالى به ودفع للضرر الذي نهى الله عنه .

المبحث الثالث: الحالات والشروط التي يسوغ فيها التسعير

أولاً: تعدي أهل السوق في قيم السلع:

اشتراط فقهاء الحنفية أن يتعدى أهل السوق تعدياً فاحشاً وقدر الحنفية التعدي الفاحش: يبيع بضعف القيمة ويعجز الحاكم عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير فلا بأس به .

ثانياً: أن يكون الإمام عادلاً:

هذا شرط ذكره بعض المالكية لأن التسعير سلاح ذو حدين إن ظلم به الإمام أرباب السلع امتنعوا عن بيع سلعهم وإن ظلم به العامة ضيق عليهم في أرزاقهم وأقواتهم فكان الإمام العادل يتحرى الإنصاف في التسعير .

ثالثاً: أن يكون السلعة المسعرة مما يحتاجها عامة الناس: بحيث لا يستطيعون الاستغناء عنها فتكون سلعة ضرورية .	رابعاً: احتكار التجار للسلع الضرورية: ينتج عنه غلاء تلك السلع .
خامساً: أن تحتكر فئة معينة بيع سلع مخصوصة: فلا تباع تلك السلع إلا لهم ولا تشتري إلا منهم فهذا يكون التسعير واجباً عليهم .	سادساً: أن يتواطأ البائعون ضد المشترين أو العكس: معناه أن البائعين إذا اتفقوا فيما بينهم على تحديد سعر معين يحقق لهم ربحاً ففاحشاً أو اتفق المشترين فيما بينهم على تحديد سعر معين للكيد بالتجار وإرغامهم على البيع بسعر معين فيه فائدة للمشتريين وفيه ضرر للبائعين كما يحدث في المزادات في زماننا هذا فإنه يحق للحاكم أو من يقوم مقامه في مثل هذه الحالة أن يتدخل لجبر الناس بالبيع بسعر محدد .

المبحث الرابع: كيفية التسعير وصفته

التسعير من قبل الإمام لا يكون إلا بعد دراسة جادة ومستفيضة لقيم الأشياء ومشاورة أهل الخبرة وأخذ رأي أهل السوق المعنيين بالسلع .

والذي نلاحظه من خلال وصف الفقهاء للكيفية التي يتم بها التسعير هو أن التسعير لا يتم خبط عشواء وإنما بناء على خطة مدروسة يقوم بها ذوو الخبرة والاختصاص .

المبحث الخامس: حكم مخالفة التسعير

أولاً: حكم البيع مع مخالفة التسعير:

ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى من خالف التسعير صح بيعه إذ لم يُعْهَدِ الحجر على الشخص في ملكه أن يبيع بثمن معين ولكن إذا سَعَّرَ الإمام وخاف البائع أن يُعْزَرَهُ الإمام لو نقص عما سعره .	وصحة البيع مع مخالفة التسعير متبادر من كلام المالكية أيضاً يقولون: ومن زاد في سعر أو نقص منه أمرٌ بإلحاقه بسعر الناس فإن أبي أخرج من السوق .	ومقابل الأصح عند الشافعية بطلان البيع لكن عند الحنابلة إن هدد المشتري البائع المخالف للتسعير بطل البيع لأنه صار محجوراً عليه لنوع مصلحة ولأن الوعيد إكراه .
---	--	---

ثانياً: عقوبة المخالف:

الحنفية والمالكية والشافعية: أن الإمام له أن يعزر من خالف التسعير الذي رسمه فيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة .

– وأما قدر التعزير وكيفيته فمفوض إلى الإمام أو نائبه وقد يكون الحبس أو الضرب أو العقوبة المالية أو الطرد من السوق .

– هذا كله في الحالات التي يجوز فيها التسعير أما حيث لا يجوز التسعير عند من لا يراه فلا عقوبة على مخالف التسعير .

(الوحدة الرابعة)

المطلب الأول: مفهوم الخيار في اللغة والاصطلاح

أولاً: في اللغة: الاصطفاء والانتقاء

ثانياً: في الاصطلاح:

- الخيار هو القدرة على فسخ العقد

- الخيار هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه .

- هو حق العاقد في فسخ العقد أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى اتفاق عقدي .

ثالثاً: حكم الخيار: مشروعية الخيار في الجملة

(1) قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما مُحَقَّ بركة بيعهما .

(2) قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال : « أو يكون بيع خيار »

(3) قال صلى الله عليه وسلم : " البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار "

(4) قال صلى الله عليه وسلم : " إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يختار أحدهما الآخر فتباعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع "

(5) ابن عمر رضي الله عنه قال: كان حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً وكان قد سُفِّعَ في رأسه مأمومه فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار فيما اشترى ثلاثاً وكان قد ثقل لسانه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بع وقل: لا خلافة " فكننت أسمعته يقول: لا خلافة لا خلافة

وجه الدلالة من الأحاديث: أفادت هذه الأحاديث بمجموعها ودلت على مشروعية الخيار في البيع

وسمي الخيار خياراً لأنه يكون فيه للمتعاقدين أو لأحدهما حق الفسخ خلال مدة معلومة أو له حق الفسخ ورد البيع لسبب معين خلال مدة معلومة مثل خيار الشرط

وله . أيضاً: أن يرد لسبب معين كوجود عيب في الصفقة وهذا يسمى خيار العيب وخيار الغبن إذا غبنه وخيار التدليس إذا دلّس عليه في السلعة .

- والفقهاء يذكرون الخيار في البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) وهذا الباب يعتبر من أهم الأبواب المتعلقة بالمعاملات .

المطلب الثاني: ثبوت الخيار وأثره في العقد

ثبوت الخيار:

أما بالشرع	أو بالشرط
ما ثبت به لا يحتاج إلى إدراجه أو النص عليه في العقد اكتفاءً باعتبار الشارع له كخيار المجلس وخيار الرؤية .	يكون اشتراطه بالنص عليه في صلب العقد صراحة (كخيار الشرط وخيار التعيين

- الدليل على ثبوت خيار المجلس بالشرع "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر"	- خيار النقد) .
- دليل ثبوت خيار الرؤية بالشرع " من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه "	

وهذه الخيارات منها ما هو:

خاص بعقد معين: كخيار البلوغ وخيار العتق والكفاءة .	يعم عدداً من العقود: كخيار الشرط وخيار الرؤية والتروي والغبن والتعيين وخيار الغبن .
--	---

أثر ثبوت الخيار في العقود: الأصل في عقد البيع أن يكون لازماً .

- وأثره سلب لزومها بجعلها قابلة للفسخ إذا استعمل من ثبت له الخيار حقه في ذلك .

أنواع الخيارات:

1. عند الحنفية: سبعة عشر نوعاً : الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب وخيار الغبن
2. المالكية: مرد الخيارات في العقود نوعين هما: خيار التروي وخيار النقيصة
3. الشافعية: التشهي والنقيصة .

فخيار التشهي: ما يكون باختيار العاقد من غير توقف على فوات أمر في المعقود عليه يقتضيه وسببه المجلس أو الشرط .

وخيار النقيصة: هو المتعلق بفوات معقود مظنون نشأ الظن فيه من قضاء عرفي أو التزام شرطي أو تغرير فعلي وفوات ما يظن حصوله بذلك .

4. الحنابلة: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرؤية وخيار الغبن وخيار العيب .

المطلب الثالث

خيار المجلس

يعرف خيار المجلس بأنه: " حق كل من المتعاقدين في فسخ العقد أو إمضائه ما دام مجتمعين في المجلس لم يتفرقا بأبدانهما " .

ومثال خيار المجلس لو أنك اشتريت سيارة بأربعين ألفاً ولو ندم البائع فله أن يرد عليك مالك

ومثال إسقاط الخيار: أن تقول : بعتك ولا خيار لي من الآن فقال : اشتريت ولا خيار لي من الآن فقد وجب البيع .

الفرع الأول: أراء الفقهاء في مدى ثبوت خيار المجلس

المذهب الأول: ثبوت خيار المجلس وأنه مشروع وثابت لكلا العاقدين والعقد لا يلزم عندهم إلا بالتفرق عن مجلس العقد أو التأخير واختيار إمضاء العقد .

المذهب الثاني: عدم ثبوت خيار المجلس و العقد لازم بمجرد حصول الإيجاب والقبول (النخعي وربيعه وإليه ذهب الحنفية والمالكية في المعتمد) .

سبب اختلاف الفقهاء:

- (١) الاختلاف في المراد بالتفريق الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار حتى يتفرقا) .
- (٢) تعارض النصوص في ظاهرها: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) والعقد يحصل بمجرد الإيجاب والقبول فيكون الوفاء به حينئذ واجباً وهذا يتعارض في ظاهره مع الأحاديث المثبتة لخيار المجلس مثل: (البيعان بالخيار حتى يتفرقا) .
- (٣) الاختلاف في القواعد الأصولية ذلك أن خيار المجلس ثابت بأخبار آحاد وقد تعارضت مع عمل أهل المدينة .

أدلة المذهبين: أدلة المذهب الأول:

من السنة

١. " إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا . ٢. " البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " . ٣. " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما مُحَقَّق بركة ببيعهما " . ٤. " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر " . ٥. " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار " . ٦. " البائع والمبتاع بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله " . <u>وجه الدلالة:</u> أفادت هذه الأحاديث ودلت بمنطوقها دلالة واضحة على ثبوت الخيار لكل من العاقلين (المتبايعين) في فسخ العقد أو إمضائه بعد تباعيهما ما لم يتفرقا بأبدانهما .	اعترض على الاستدلال بالأحاديث السابقة بما يلي: (أ) حديث ابن عمر خبر واحد في أمر تَعُمُّ به البلوى ولذا فإنه لا يقبل بالعمل وأجيب عنه: بأن حديث ابن عمر من أوثق الأسانيد وأصحها . _ خبر الواحد يُقبل فيما تَعُمُّ به البلوى وفيما تخص به البلوى . (ب) روايات حديث ابن عمر محمولة على خيار القبول قبل البت في العقد . (ج) الحديث خبر آحاد وهو يفيد ظن الثبوت وعمل أهل المدينة مقدم عليه لأنه كالحديث المتواتر . (د) إن الحديث منسوخ والذي اجتمع عليه أهل العلم من أهل الحجاز أن البائعين إذا أوجبا البيع بينهما فقد لزم . وأجيب عن هذا بما يلي: إنه لا حجة في شيء من ذلك لن النسخ لا يثبت بالاحتمال . (هـ) إن حديث ابن عمر برواياته مخالف لظاهر الكتاب الكريم فإنه مخالف لقول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم "
--	--

ثانياً: إجماع الصحابة:

إن ثبوت خيار المجلس للعاقلين مروى عن ابن عمر وأبي هريرة والأسلمي وعلي وابن عباس وأبي هريرة وعثمان ولم يعرف لهم (رضي الله عنه) في الصحابة مخالف فكان هذا إجماعاً منهم على ثبوته .

ثالثاً: المعقول:

حاجة الناس داعية إلى هذا النوع من الخيار فقد يبيع المرء شيئاً ثم يبدو له فيندم فبالخيار الثابت له يمكنه تدارك ما ندم بسببه .

أدلة المذهب الثاني:- أولاً: الكتاب الكريم:

(١) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم) . وجه دلالة الآية: لم تشترط في إباحة التجارة سوى التراضي من الطرفين لا غير والتراضي إنما يحصل بمجرد صدور الإيجاب واقتترانه بالقبول فيدل ذلك على عدم ثبوت خيار المجلس . (٢) يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) . وجه دلالة الآية: تنص على وجوب الوفاء بالعقود والعقد يتم بالإيجاب والقبول فلو كان خيار المجلس ثابتاً لم يكن الوفاء بالعقد لازماً وهذا خلاف النص . (٣) (وأشهدوا إذا تباعتم) . وجه الدلالة من الآية: ندبت الآية الكريمة إلى الإشهاد عند البيع دفعاً لوقوع التجاحد والبيع يصدق بالإيجاب والقبول فيكون الإشهاد عند حصولهما غير أنه إذا اعتُبر خيار المجلس وكان لأحدهما الفسخ بعد العقد المشهود عليه بمقتضى خيار المجلس لم يعد للإشهاد أية فائدة .	اعترض على الاستدلال بهذه الآيات الكريمة بما يلي: بأن هذه الآيات وإن كانت مطلقة إلا إن إطلاقها قُيِّد بما ورد في الأحاديث المثبتة لخيار المجلس والمطلق محمول على ما يقيد كما أن عمومها مخصوص بتلك الأحاديث . وعليه: فاشتراط الرضا (إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم) لا ينافي الخيار لأنه من تمامه وتمائم الشيء منه . وجوب الوفاء بالعقود والشروط إنما يكون ذلك بعد اكتسابها صفة اللزوم .
---	---

ثانياً: السنة النبوية المطهرة:

(١) ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا اختلفت البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول ربُّ السلعة أو يتتاركان" .

(٢) قوله ﷺ "أَيُّمَا بَيِّعِينَ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانَ" .

وجه الدلالة: المتبايعين قد يختلفان قبل الافتراق وأنه يعتد بقول البائع عند اختلافهما فإن لم يحلف تتاركا فلو كان لكل من المتبايعين الخيار في إمضاء العقد أو فسخه لم تجب على البائع يمين ولا ترداد .

(٣) قوله ﷺ: "لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفسه" .

(٤) قوله ﷺ: "... والمسلمون على شرة طهم إلا شرطاً حرمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً" .

وجه الدلالة من الحديثين:

الحديث الأول أن حل مال الغير مترتب على مجرد طيب نفسه به ودل الثاني أن ما عقده المسلمون أو اشترطوه فإنه لازم لهم بمجرد العقد والشرط ولم يرد في الحديثين تقييد ذلك بالتفرق عن المجلس فدلا على عدم ثبوت خيار المجلس .

(٥) "إذا ابتعت الطعام فلا تبعه حتى تستوفيه" قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء بمنزلته" .

وجه الدلالة: يدل بمنطوقه على أن من اشترى طعاماً فلا يحل له بيعه حتى يستوفيه ويدل بمفهوم المخالف أنه إذا استوفاه جاز له بيعه فأجاز بيعه مطلقاً ولم يقيد بالتفرق من المجلس فدل على ثبوت الملك للمشتري .

(٦) النبي ﷺ: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقبله" .

وجه الدلالة: قد نهى كلا من العاقلين عن مفارقة صاحبه مخافة أن يستقبله: أي يسأله الإقالة وهذا يدل على نفي خيار المجلس من وجهين:

(أ) لو كان ثابتاً لكلا العاقلين لما احتاج كل منهما إن يسأل صاحبه الإقالة بل له أن يفسخ مطلقاً .

(ب) أن الإقالة لا تكون إلا بعد صحة العقد فدل أن العقد قد تم ولزم بمجرد الإيجاب والقبول قبل الافتراق .

اعترض على الاستدلال بهذه الأحاديث: أنها أحاديث عامة خصصتها الأحاديث الدالة على ثبوت خيار المجلس

ثالثاً: القياس: قياس عقود المعاوضات المحضة على النكاح والخلع والكتابة والعق على مال في أنها جميعاً من المعاوضات التي تتم بمجرد الصيغة الدالة على رضا الطرفين بها دون خيار المجلس فكان خيار المجلس غير ثابت في المعاوضات المحضة بمقتضى هذا القياس .

اعترض على هذا: بأنه قياس في مورد النص وهو قياس فاسد

وقياس البيع على النكاح لعدم إثبات خيار المجلس مردود عليه: بأن عقد النكاح لا يقصد منه المال بل يقصد منه الوصلة بين الزوجين ولهذا لم يشرع فيه الشرط وهذا بخلاف عقد البيع

كما إن عقد النكاح لا يقع . غالباً . إلا بعد رؤية ونظر ومكث فلم يكون بحاجة إلى خيار بعده

وفي إثبات خيار المجلس في عقد النكاح مضرة للمرأة لما يلزم من رد المرأة بعد العقد عليها من ابتذال لها وإذهاب لحرمتها

٢. خيار المجلس مجهول المدة فكان بمثابة اشتراط مجهول وذلك مفسد للعقد باعتبار اشتمال اشتراطه على جهالة فاحشة .

واعترض على هذا: بأن جهالة زمن خيار المجلس لا أثر له في ثبوته وصحته لأنه خيار ثابت بالشرع .

٣. إن العقد صدر من العاقدین مطلقاً عن شرط خيار المجلس والعقد المطلق يقتضي ثبوت الملك في العوضين في الحال فإذا فسخ أحدهما يكون قد تصرف في العقد الثابت بتراضيهما بالفسخ من غير رضا الآخر وهذا لا يجوز .

4. إن العقد بعد تفرق المتعاقدين عقد لازم غير قابل للفسخ فيقاس ما قبل التفرق على ما بعده باعتبار أنه لم يحدث بعد التفرق ما يوجب اختلاف حكم العقد عما قبل التفرق وهذا يقتضي عدم ثبوت خيار المجلس .

واعترض على هذا: قياس فاسد لأنه قياس في مورد النص وهذا لا يجوز .

الرأي الراجح: الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور .

❖ الفرع الثاني أمد خيار المجلس

من وقت إتمام العقد بالإيجاب والقبول إلى وقت انتهائه بالتفرق عن مجلس العقد أو التخاذل وبين حقيقة كلا منهما على النحو التالي:

(1) أولاً: التفرق عن المجلس: ينتهي خيار المجلس بالتفرق ويراعى فيه عرف المتعاقدين وأنه بهذا

التفرق يصير العقد لازماً غير قابل للفسخ بخيار المجلس .

– والتفرق المُنهي لخيار المجلس هو التفرق بالأبدان بأن يمشي كل من المتعاقدين عن الآخر بحيث يصير له مكان غير مكان صاحبه بحيث إذا كلمه الكلام المعتاد في المجلس لا يسمعه .

ومما استدلوأ به على انتهاء الخيار بالتفرق بالأبدان:

– البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر .

– البيعان بالخيار ما لم يتفرقا .

- كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار .

وكل ما سبق من الأحاديث يدل دلالة واضحة على ثبوت خيار المجلس بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانها .

- قال صلى الله عليه وسلم " البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقبله " .

وجه دلالة الحديث: الشاهد في قوله " ولا يحل له أن يفارقه.. " وهو يقوّي استدلالهم بالمعنى الذي وقفوا عنده وهو التفريق بالأبدان .

(2) **ثانياً: التخيير (أو التخيير):** اختيار لزوم العقد على أن يحصل ذلك من العاقدين كليهما فيسقط به الخيار وسبيله أن يقول: اخترنا لزوم العقد أو أمضيناه أو ألزمناه أو أجزناه أو نحوه .

الخلاص في التخيير:

الشافعية وجمهور الحنابلة	روى عن الإمام أحمد
انتهاء خيار المجلس بالتخيير ودليلهم: قوله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر " . "إذا تباع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فتباعا على ذلك فقد وجب البيع . والأخذ بالزيادة أولى والتخيير في ابتداء العقد وبعده في المجلس واحد فالتخيير في ابتدائه أن يقول: بعثك ولا خيار بيننا وبقبل الآخر على ذلك والتخيير بعده أن يقول كل واحد منهما بعد العقد: اخترت إمضاء العقد أو إلزامه .	أن انتهاء مجلس العقد يكون بالتفرق دون التخيير

الراجع: من يرى انتهاء الخيار بالتخيير لثبوت الأحاديث الدالة عليه .

الفرع الثالث:

ثبوت خيار المجلس في العقود

- خيار المجلس لا يثبت إلا في عقود المعاوضات المحضة كالبيع والإجارة والسلم .
- أما عقود المعاوضات غير المحضة كالنكاح والخلع والطلاق على مال والصلح عن دم العمد وإن كان لازمة من الطرفين إلا أنه لا يتمخض معاوضة فلا يثبت فيها خيار المجلس لأن طبيعتها تأباه .
- لا يثبت خيار المجلس في العقود الجائزة من الطرفين (وهي عقود ليست لازمة في حق أي من طرفيها) كالعارية والوديعة والوكالة والشركة والوصية ونحوها .
- لا يثبت في العقود الجائزة في حق أحد الطرفين لازمة في حق الآخر وهي عقود التوثيق كالرهن والكفالة .
- ولا يثبت العقود التي تبدأ جائزة ثم تؤول إلى اللزوم كالجعالة قبل شروع العامل في العمل .
- وعلة عدم ثبوت خيار المجلس في العقود الجائزة من الطرفين أو من أحدهما أو التي تؤول إلى اللزوم بوسع العاقد الذي كان العقد في حقه جائزاً أن يفسخ العقد بإرادته المنفردة دون حاجة إلى إثبات هذا الخيار له .

الفرع الرابع:

آثار خيار المجلس في العقود:

لخيار المجلس آثاراً مختلفة لكن أحدها يعتبر الأثر الأصلي للخيار في حين تكون الأخرى آثاراً .

أولاً: الأثر الأصلي: منع لزوم العقد:

اعتبار العقد غير لازم إلى أن يحصل التفريق أو اختيار إمضاء العقد وهذا الأثر متفق عليه عند القائلين بخيار المجلس .

ثانياً: الأثر الفرعي: انتقال الملك في المعقود عليه قبل التفريق عن المجلس:

القول الأول	القول الثاني	القول الثالث
الملك ينتقل إلى المشتري مع وجود خيار المجلس ولا أثر له على صحة نفاذ العقد . الأدلة: 1- من السنة: ابن عمر: سمعت رسول الله: "من ابتاع نخلاً بعد أن تُؤبّر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع". <u>وجه الدلالة:</u> أنه جعل المال المصاحب للعبد والثمرة للمبتاع بمجرد اشتراطه وإن لم يحدث تفرق عن المجلس أو تخاير مما يدل على أن الملك فيها ينتقل قبله . 2- من المعقول: أن البيع وما في حكمه من العقود تفيد انتقال الملك في المعقود عليه ولا منافاة بين ثبوت الخيار وانتقال الملك بهذه العقود . - وجود الخيار في العقد لا يؤثر في صحته فهو صحيح مع وجود الخيار وانتقال الملك أثراً من آثار العقد الصحيح فإنه يترتب وإن وجد الخيار في العقد.	"تقييد النفاذ" بمعنى أن لخيار المجلس أثراً في انتقال الملك في المعقود عليه حيث يوقف نفاذه وغيره من آثار العقد حتى يتم التفريق أو التخيير . الدليل: أن مقتضى ثبوت خيار المجلس للمتصرف في الشيء عدم انتقال الملك في المتصرف فيه إلى غيره ومقتضى ثبوته للمتصرف إليه انتقال هذا الملك إليه ومن ثم وجب التوقف إلى أن ينتهي الخيار .	لخيار المجلس أثراً في ترتب آثار العقد عليه في الحال حيث يمنع من انتقال الملك ونحوه من آثار العقود إلى ما بعد انقضاء التخيير وأما قبله فيظل ملك كل عوض باقٍ لصاحبه وهو رأي الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد . الدليل: أن النبي ﷺ قال: : كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار " . <u>وجه الدلالة:</u> أن النبي ﷺ نفى أن يكون بينهما بيع قبل التفريق عن المجلس والنفي في الحديث ليس لذات العقد لوجوده بمجرد الإيجاب والقبول وإنما النفي لآثاره التي منها انتقال الملك .

المطلب الثالث: خيار الشرط

والشرط لغة: إلزام الشيء والتزامه .

وخيار الشرط في الاصلاح قال ابن عابدين:

ما يثبت (بالاشتراط) لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء والفسخ

الفرع الأول: العقود التي يدخلها خيار الشرط .

القسم الثاني ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال ولكن قد يفضي إلى اللزوم في ثاني حال . وهو: الجعالة: وهي قول الرجل: من جاءني بعبدني الأبق فله دينار . والعتق بعوض كقوله: أعتق عبدك عني بدينار . واستهلاك الأموال بالضمان كقوله: ألق متاعك في البحر وعلي قيمته . والقرض والهبة فهذه العقود الخمة غير لازمة في الحال .	القسم الأول ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال ولا يفضي إلى اللزوم في ثاني حال . وهو خمس عقود: الوكالة والشركة والمضاربة والعارية والوديعة فالخيار فيها مؤبد من جهتي المتعاقدين معاً فإن شرط فيها إسقاط الخيار بطلت لأنها تصير بإسقاط الخيار لازمة وهي عقود جائزة غير لازمة .
القسم الرابع ما كان لازماً من جهة المتعاقدين في الحال . أحدها: ما لا يثبت فيه الخيار لواحد من المتعاقدين بحال وذلك ثلاثة عقود: النكاح والخلع والرجعة، فإن شرط فيها أحد الخيارين بطلت . والثاني: ما لا يدخله خيار الشرط (الإجازة والمساقاة والحوالة) . والثالث: ما لا يدخله خيار الشرط ويدخله خيار المجلس: وهو ما كان القبض قبل الافتراق شرطاً في صحته (الصرف والسلم) فإن شرط فيها خيار الثلاث بطلا . والرابع: ما يدخله خيار المجلس بغير شرط وخيار الثلاث بالشرط وهو سائر عقود البياعات وقال أبو حنيفة ومالك: البيع لازم الإيجاب والقبول ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال .	القسم الثالث ما كان لازماً من جهة أحد المتعاقدين في الحال دون العاقد الآخر بكل حال . وهو ثلاثة عقود: الرهن والضمان والكتابة فالخيار فيها ثابت للمرتهن دون الراهن وللمضمون له دون الضامن وللمكاتب دون السيد .

حكمه: لا خلاف في جواز خيار الشرط لما روي أن حبان بن منقذ كان قد شج في رأسه مأمومة فنقل لسانه وكان يخدع في البيع فجعل له رسول الله ﷺ ما يبيع من شيء فهو بالخيار ثلاثاً وقال رسول الله ﷺ: " قل لا خلابة " أي لا خديعة .

– ولأن عقد البيع عقد معاينة والمقصود منه الاسترباح ولا يمكن تحصيل ذلك إلا أن يرى النظر فيه ويريه بعض أصدقائه فلذلك كان محتاجاً إلى اشتراط الخيار .

الفرع الثاني: مدة الخيار

لا خلاف بين الفقهاء الأربعة على جواز اشتراط الخيار ثلاثة أيام فما دونها .

– الاختلاف بينهم فيما زاد على ثلاثة

المذهب الأول	المذهب الثاني	المذهب الثالث	المذهب الرابع
البيع جائز والشرط لازم إلى الأمد الذي اشترط إليه المتبايعان الخيار . (أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل)	يجوز شرط الخيار في المبيعات على قدرها وبحسب ما تدعو إليه الحاجة في تعرف أحواله . (المالكية)	يجوز شرط الخيار للمشتري عشرة أيام وأكثر ولا يجوز شرطه للبائع . (سفيان الثوري)	الخيار في البيع ثلاثة أيام ولا تجوز الزيادة عليها فإن زاد فسد البيع . (الشافعية وزفر بن الهذيل وأبو حنيفة النعمان)
" المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار " . <u>وجه الدلالة:</u> دل على أن الخيار على الإطلاق دون توقيت مدة . – عن ابن عمر قال: قال رسول الله: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار " . <u>وجه الدلالة:</u> الاستثناء هنا من مفهوم الغاية أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا ثانياً: عمل الصحابة: عن عمر (رضي الله عنه) أنه أجاز الخيار لرجل في ناقة شهرين . من المعقول: – أن هذه مدة ملحقة بالعقد شرطاً فلا تتقدر بالثلاث كالأجل . – ولأن ما زاد على الثلاث كالثلاث في المعنى الذي لأجله جوزنا شرط الخيار .	أ. أن العبد والجارية لا يعرف أخلاقهما ولا ما هما عليه من الطباع في مدة الثلاث لأنهما يتكلفان ما ليس من طبعهما في مدة يسيرة ثم يعودان بعد ذلك إلى الطبع فوجب أن يكون الخيار مدة يختبران في مثلها ليكون المبتاع داخلاً على بصيرة ب. أجل العنين سنة لأن حاله يختبر فيها فكذاك ينبغي أن يكون كل خيار على حسب تعرف حال المختبر .	بأن الخيار ثبت على خلاف القياس فيقتصر على مورد النص ومورد النص فيه للمشتري . <u>مناقشة هذا الدليل:</u> بأن النص " إذا بايعت " يتناول البيع والشراء فيجوز لهما وكان بالناس حاجة إليه ليدفع الغبن بالتروى وفيه يستوي البائع والمشتري .	1- من السنة: حديث {كان حبان بن منقذ رجلاً ضعيفاً وكان قد سَفَع في رأسه مأمومة} . <u>وجه الدلالة:</u> والخيار مخالف لوضع البيع في منع نقل الملك أو في منع لزومه فثبت الخيار حائد عن الموضوع فيتعين التوقيف فيه فليس في إثباته غير الإتيان وقد ورد الخبر في إثبات الثلاث فينعي التوقف عنده فلا يجوز الزيادة عليها . كما أن حبان كان أحوج الناس إلى الزيادة في الخيار لمكانه من ضعف النظر وحاجته إلى استدراك الخديعة ومع ذلك لم يزد النبي . – عن النبي قال: " من اشترى مصراً فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعاً من تمر لا سمراء " . قدر النبي مدة الخيار في المصرة بثلاثة أيام والتقدير الشرعي إما أن يكون لمنع الزيادة والنقصان أو لمنع أحدهما وهذا التقدير ليس لمنع النقصان فاشتراط الخيار دون ثلاثة أيام يجوز فعرفنا أنه لمنع الزيادة . <u>مناقشة هذا الدليل:</u> نوقش من قبل المالكية بأن هذا الحديث جحة لنا لأن المصرة لما كان يختبر أمرها في أقل من ثلاثة أيام جعل فيها هذا المقدار الذي يختبر في مثله وكل مبيع يختلف عن الآخر في مدة اختباره . ثانياً: من المعقول: الخيار يمنع من التصرف وموجب العقد جواز التصرف والشرط إذا كان منافياً لموجب العقد أبطله كما لو باعه بشرط أن لا يتصرف فيه ببيع أو غيره .

الترجيح: الرأي المستحق للترجيح هو الرأي القائل بعدم قصر المدة على ثلاثة أيام وأنها لا تكون إلى الأبد فتخرج العقد عن غايته وتكون معلومة بما يحقق غرض العقد والتروى فتتوقف على نوع المبيع كما يقوله المالكية .

فإن شرط في الخيار مدة مجهولة

الشافعية	الأحناف	ابن أبي ليلى	الحنابلة	المالكية
بطل الشرط والبيع	فسد لأنها مدة ملققة بالعقد فلم يجز مع الجهل بها كالأجل . وقال أبو حنيفة: إن أسقطا الشرط قبل مضي الثلاث أو حذف الزائد على مدة الثلاث وبيننا مدته صح لأنهما حذف المفسد قبل اتصاله بالعقد فوجب أن يصح كما لو لم يشراطاه .	الشرط باطل والبيع صحيح	الشرط صحيح والبيع صحيح وهما على خيارهما أبداً أو يقطعان المدة .	يصح وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة لأن ذلك مقدر في العادة فإذا أطلقا حمل عليه .

الفرع الثالث

متى تبدأ المدة في خيار الشرط؟ مدة الخيار من حين العقد لا من وقت التفرق .

الفرع الرابع:

ملك المبيع في زمن الخيار

المبيع قبل البيع ملك للبائع وبعد لزوم البيع يكون من ملك المشتري .

- واختلف الفقهاء في المبيع في زمن الخيار هل يكون خرج عن ملك البائع إلى المشتري أم أنه ما زال على ملكه؟ أربعة مذاهب:

المذهب الأول	المذهب الثاني	المذهب الثالث	المذهب الرابع
(المالكية والشافعية والإمام أحمد) أنه لا ينتقل ملك المبيع عن البائع حتى ينقضي الخيار . 1- من الكتاب: "بَيَّهَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ" . تمام البيع يكون بالتراض ولا يتم الرضا مع الخيار فلم يتم السبب في حق الحكم . 2- من السنة: أن النبي ﷺ قال: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر " . نص على عدم انعقاد البيع قبل الافتراق فدل على أن الملك إنما يحصل بالافتراق وانتهاء الاختيار . 3- من المعقول: أن حصول	إذا كان الخيار للمتبايعين معاً أو للبائع وحده كان المبيع على ملك البائع في مدة الخيار فإذا انقضت مدة الخيار ملكه المشتري حينئذ بالعقد المتقدم . إن كان الخيار للمشتري وحده فالمبيع قد زال عن ملك البائع بالعقد ولا يملكه المشتري إلا بعد انتهاء مدة الخيار فإذا انقضت ملكه بالعقد المتقدم . الدليل لأن خيار إذا كان للمشتري فإنه يكون قد انتقل عن ملك البائع للزوم البيع من جهته ولكن لا يدخل في ملك المشتري حتى لا يجتمع البدلان في ملك إنسان وهو المبيع والتمن	موقوف فإن انقطع الخيار بان أن المشتري كان ملكاً للمبيع وإن نقض الخيار عن فسخ بان المبيع لم يزل على ملك البائع (قول عند الشافعية) ..الدليل . العقد يثبت للملك والخيار ينفي الملك وأمرهما يتردد بين أن يغلب حكم العقد وبين أن يغلب حكم الخيار فصصار كالقبض الذي يقتضيه العقد ويقف تصحيحه عليه فإن انقضى عن تراض بأن صحة العقد . وانتقال الملك وإن	ينتقل إلى المشتري في زمن الخيار وهذا ما ذهب إليه الحنابلة في ظاهر المذهب . الدليل 1- من السنة: قال ﷺ: " المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا " فسماهما متبايعين فدل على حصول البيع وموجب البيع حصول الملك . 2- من القياس: خيار العيب لا يمنع من حصول الملك فكذلك خيار العقد لا يمنع من حصول الملك . 3- من المعقول: الأملاك تستفاد بأحد وجهين: بقول ويفعل فلما كان ما يملك بالفعل كالاصطياد والاحتشاش لا يكون مرور الزمان مؤثراً في تملكه وجب أن يكون ما يملك بالقول كالبيع

الملك يقتضي ثبوت موجبه وموجب الملك جواز التصرف فلما كان المشتري ممنوعاً من التصرف دل على أن الملك غير منتقل .	انقضى عن فسخ بان بطلان العقد وأن الملك لم ينتقل به .	والهبة لا يكون مرور الزمان أيضاً مؤثراً في تملكه .
---	--	---

ثمرة الخلاف: فيما لو باع البائع المبيع في زمن الخيار أو وهبه أو تصدق به إلى غير ذلك فعلى رأي من يقول إن الملك بقى على ملك البائع فيكون تصرفه هذا صحيحاً لأنه باع ما يملكه . وعلى رأي من يقول بعدم بقاء الملك عليه سواء انتقل إلى المشتري أو هو موقوف فتصرفه هذا باطل لأنه باع ما لا يملكه .

المطلب الرابع:

خيار العيب

أن يثبت للمشتري الحق في فسخ العقد أو إمضائه إذا اطلع على عيب لم يكن قد اطلع عليه إثناء العقد ولم يكن هذا مشروطاً في عقد البيع .

الفرع الأول: العيب الذي يثبت به الخيار

العيب الذي يوجب نقصاً في المالية في عادة التجار لأن المبيع إنما صار محلاً للعقد باعتبار صفة المالية فما يوجب نقصاً فيها يكون عيباً وكذلك يكون عيباً إذا فوت على المشتري غرضاً صحيحاً كالمرض في الدابة وكالقطع في أذن الشاة المشتراة في الأضحية .

الفرع الثاني

شروط العيب الموجب للخيار .

- 1- أن يكون العيب قديماً أي أن يكون العيب موجوداً بالمبيع وهو في يد البائع .
ويثبت قدم العيب بإقرار البائع به أو أن يكون العيب غير ممكن حدوثه في المدة التي تسلم فيها المشتري المبيع أو بإثبات المشتري ذلك بالبينة .
- 2- ألا يكون المشتري عالماً بالعيب عند العقد أو عند القبض .
- 3- ألا تحصل حال تدل على رضا المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه .
- 4- أن يكون العيب موجباً لنقصان قيمة المبيع في عرف التجار أو مفوتاً غرضاً مقصوداً من المبيع .
- 5- ألا يكون العيب مما يمكن إزالته بدون مشقة فإن اشترى ثوباً متنجساً لا يضره الغسل لم يكن هذا عيباً يوجب الفسخ .
- 6- ألا يزول ذلك العيب قبل الفسخ .
- 7- ألا يشترط البائع في البيع براءته من دعوى العيب كأن يقول البائع بعثك هذه السلعة على أنني بريء من كل عيب فيها وقبل المشتري هذا فلا يكون له الحق في الرد وهذا ما ذهب إليه الحنفية وقول عند الشافعية .

- وذهب المالكية والحنابلة والشافعية في القول الثاني أن البائع لا يبرأ إلا من العيوب التي عينها وذكرها المشتري .

❖ الفرع الثالث: بيع المصرة

التصرية لغة: الجمع .

اصطلاحاً: ربط خلاف الناقاة أو الشاة وترك حلبها ليجتمع لبنها فيظن المشتري أن ذلك عادتها .

حكمها: حرام إذا قصد به التدليس على المشتري لنهييه صلى الله عليه وسلم "لا تُصِرُّوا الإبل والغنم" .

ولأنه غش وقد نهى عنه أيضاً "من غشنا فليس منا" .

حكم البيع إذا حدث: إن كان اشتراط الخيار ثلاثة أيام ثبت له حق الرد وهذا مما أجمع عليه الفقهاء وأما إذا لم يشترط الخيار فوجد الشاة مصرة فقد اختلف الفقهاء فيه على مذهبين:

أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : لا يثبت له الخيار	الجمهور أنه يثبت للمشتري الخيار
1. مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع وبقلة اللبن لا تنعدم صفة السلامة لأن اللبن ثمرة وبعدمها لا تنعدم صفة السلامة . 2. الخيار لا يثبت الغرور لأن المشتري مغتر لا مغرور فإن انتفاخ الضرع قد يكون بكثرة اللبن فيه وقد يكون بالتحفيل وعلى ما ظهر من عادات الناس احتمال التحفيل فيه أظهر فيكون المشتري مغترراً في تباطئه على المحتمل والمحمّل لا يكون حجة خاصة . مناقشة هذا الدليل: اغترار المشتري هنا إنما حدث بتدخل من البائع وكذلك أن التصرية منهي عنها فإذا فعلها كانت عيباً لخروجه عن المعهود شرعاً	أولاً: من السنة: 1. قال صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصرة فهو بخير النظرين فإن ردها رد معها صاعاً من تمر لا سمراء . 2. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله: "ومن اشترى شاة محفلة فله أن يمسخها ثلاثاً فإن رضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعاً من تمر" . 3. عن عبد الله بن مسعود قال: "ومن اشترى شاة محفلة فردّها فليرد معها صاعاً من تمر" . فقد بينت هذه الأخبار أن التصرية عيب يوجب الخيار للمشتري في الإمساك أو الرد. مناقشة هذه الأدلة: هذه الأحاديث أخبار أحاد قد خالفت الأصول فلا يجب العمل بها. فأما مخالفتها الأصول فلأنها أوجب غرم اللبن مع إمكان رده ولأنه جعل قيمة اللبن مقدرة لا تزيد ولا تنقص مع أن القيمة تزيد بزيادة المقوم وتنقص بنقصانه . الجواب عن هذا الاعتراض: - هذه الأخبار غير مخالفة للأصول - وذلك لأن اللبن لا يمكن رده لنقصان قيمته بالحلب وذهاب كثير من منافعه بطول المكث . ثانياً: من المعقول: التصرية تدليس من البائع يختلف به الثمن لأن المشتري يرغب في كثيرة اللبن فيزيد في سعرها عن غيرها من مثيلاتها من قليلة اللبن فجاز له ثبوت الخيار كسائر العيوب .

الراجع: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هو الراجح عملاً بالنص .

ما يجب رده مع المصرة :

الحنابلة وبعض الشافعية	المالكية وبعض الشافعية	أبو يوسف وبعض الشافعية
صاعاً عن تمر لقوله صلى الله عليه وسلم " وصاعاً من تمر لا سمراء " .	صاع من غالب قوت البلد اعتباراً بركة الفطر ولأن في بعض طرق الحديث "ورد معها صاعاً من طعام" .	يرد قيمة اللبن لأنه ضمان متلف فكان مقدراً بقيمته كسائر المتلفات .

والراجع: أرى أن ما ذهب إليه المالكية هو الراجح .

وحكم التصرية في الإبل والبقر والغنم سواء لأن التصرية في الإبل والغنم دليل على أن ما بينهما لاحق بهما ولأن البقر من جملة الغنم التي تقصد ألبانها وكذلك الجاموس .

المطلب الخامس: خيار الرؤية

هو أن يثبت الحق في فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية المشتري للمبيع وذلك لعدم العلم بالمبيع عند العقد .

حكمه: اختلف الفقهاء في مشروعيته على مذهبين:

الجمهور مشروعية خيار الرؤية وثبوته للمشتري	الشافعي في الجديد وأحمد في قول إلى عدم مشروعية خيار الرؤية.
1- من السنة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: " من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه " . يدل الحديث بمنطوقه الصريح على ثبوت خيار الرؤية . مناقشة هذا الدليل: الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به . الجواب عن هذا الاعتراض: هذا الحديث قد روي من طرق أخرى يقوي بعضها بعضاً . 2- من الأثر: روي أن عثمان باع أرضاً بالبصرة من طلحة بن عبيد الله فقبل لطلحة بن عبيد الله: إنك قد غبت فقال: لي الخيار لأنني اشتريته ما لم أره فاختصما إلى جبير بن مطعم ف قضى بالخيار لطلحة وكان ذلك بمحضر من الصحابة . 3- المعقول: فلأن المبيع أحد العوضين فلا تشترط رؤيته للاتعقاد كالثمن ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا تقضي إلى المنازعة مع وجود الخيار فإنه إذا لم يوافقه رده عند الرؤية لعدم اللزوم .	من السنة: - النبي ﷺ "أنه نهى عن بيع الغرر" . مناقشة هذا الدليل: بيع الغرر هو ما كان مجهول العين وما هنا ليس كذلك . - عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله! الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك " . مناقشة هذا الدليل: نهيه ﷺ أي ما ليس في ملكه وهو واضح من نص قول حكيم . من المعقول: أوصاف المبيع مجهولة وطريق معرفتها الرؤية دون الخبر . مناقشة هذا الدليل: الجهالة التي تفسد العقد إنما هي الجهالة التي تفضي إلى المنازعة وأما الجهالة التي لا تفضي إلى المنازعة لا تفسد العقد كبيع الفيز من الصبرة وجهالة الأوصاف بسبب عدم الرؤية لا تفضي إلى المنازعة .

الراجع: الرأي الأول .

مدة خيار الرؤية: اختلف الفقهاء فيها:

: الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية	بعض الشافعية والإمام أحمد في رواية	محمد بن الحسن :
يثبت عند رؤية المبيع ويكون للمشتري الحق في فسخ العقد أو إمضائه على الفور بمقدار ما يتمكن من الفسخ فإن لم يفسخ سقط خياره ولزم العقد . - وذلك لأنه إنما ثبت لدفع الضرر الذي يلحق المشتري من عدم رؤيته للمبيع ثم إذا رآه فقد زال الضرر فإن لم يرد ذلك على رضاه بالمبيع .	:: تنقيد بمجلس الرؤية الذي وجدت فيه لأنه خيار ثبت بمقتضى العقد من غير شرط فيتقيد بالمجلس كخيار المجلس .	أنه مطلق غير مقيد بوقت وللمشتري الفسخ ما لم يوجد منه فعل يدل على الرضا أو يوجد منه قول يسقطه وذلك لأن النص ورد مطلقاً والعبرة في المنصوص عليه لعين النص لا للمعنى .

الراجع: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه يثبت للمشتري عند رؤية المبيع صيانة للعقود وقطع النزاع .

(الوحدة الخامسة)

المطلب الأول: تعريف الربا وحكمه وحكمة تحريمه

الفرع الأول: تعريف الربا

الربا لغة: الفضل والزيادة

والربا شرعاً:

الحنفية بأنه: فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة	المالكية: الربا هي الزيادة من العَدَّ أو الوزن محققة أو متوهمة أو التأخير .	الشافعية : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البديلين أو أحدهما .	الحنابلة تفاضل في أشياء ونسء في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها .
---	---	--	---

الفرع الثاني: حكم الربا

الربا من الكبائر بل من السبع الموبقات ولم يؤذن الله تعالى في كتابه عاصياً بالحرب سوى أكل الربا .

أولاً: القرآن الكريم: " وأحل الله البيع وحرم الربا "

وجه الدلالة: الله سبحانه أحل البيع لما فيه من تبادل المنافع وحرم الربا لما فيه من الضرر الفادح بالفرد والمجتمع لأن فيه زيادة مقتطعة من جهد المدين ولحمة .

ثانياً: السنة النبوية المطهرة:

1- اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها أكل الربا .

وجه الدلالة: ذكر صلى الله عليه وسلم في السبع الموبقات وعدّ منهن أكل الربا وفيه وعيد عظيم .

ثالثاً: الإجماع: أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة .

الفرع الثالث: حكمة تحريم الربا

ولتحريم الربا حكم كثيرة في جوانب متعددة منها:

أولاً: الجانب الأخلاقي:	ثانياً: الجانب الاجتماعي:	ثالثاً: الجانب الاقتصادي:
1- أن الربا يسد طريق المعروف والإحسان إلى الناس . 2- أن في الربا ظلم وضرر للفقير وحرم الربا الذي فيه أخذ المال من المحتاجين .	1- الغالب أن المقرض يكون غنياً والمستقرض يكون فقيراً فالقول بجواز عقد الربا تمكين من يأخذ من الفقير الضعيف مالاً زائداً وذلك غير جائز برحمة الرحيم . 2- أن الربا فيه اعتصار الضعيف لمصلحة القوي ونتيجته أن يزداد الغني غنى والفقير فقراً .	1- لما فيه من أخذ فضل على ماله مع بقاء ماله في المعنى فيكون أكلاً للمال بالباطل كأخذه بالقرار . 2- أنه سبب في محو بركة المال وعدم نماءه لهذا قال الله تعالى: " يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ " و " وَمَا عَاتَيْنَا مِنْ رَبٍّ لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ " . 3- أن الاعتماد على الربا يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف عليه اكتساب وجه المعيشة فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والصناعان الشاقة والتجارة وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق .

المطلب الثاني: أنواع الربا

الربا نوعان نسيئة وفضل وزاد الشافعية نوعاً ثالثاً وهو ربا اليد .

الفرع الأول:

ربا النسيئة: تعريفه - صورته - حكمه

النسيئة لغة: من النساء وهو التأخير .

اصطلاحاً: الزيادة في الدين نظير الأجل أو مبادلة المال بالأجل أو هو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل .

ثانياً: صورة ربا النسيئة:

- كان الربا في الجاهلية أن يكون لرجل حق عند رجل إلى أجل فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذه وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل .

- أيضاً أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدرأ معيناً ويكون رأس المال باقياً ثم إذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به .

ثالثاً: حكم ربا النسيئة:

أجمعت الأمة على تحريم ربا النسيئة من غير تكير واستدلوا:

أولاً: القرآن الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ *"

وجه الدلالة: يا أيها الذين آمنوا صدقوا بالله وبرسوله وخافوا الله على أنفسكم فاتقوه بطاعته ودعوا ما بقي من الربا إن كنتم محققين إيمانكم قولاً وتصديقكم بالسننكم بأفعالكم .

ثانياً: السنة النبوية المطهرة .

1- لعن رسول الله ﷺ أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: "هم سواء" .

وجه الدلالة: دل على أن موكل الربا "وهو كل من يدفع لغيره فائدة ربوية" عاص وآثم ومرتكب لكبيرة لأن النبي ﷺ نهى عن إعطاء الربا .

2- أن رسول الله ﷺ في حجة الوداع خُطِبَ الناس وقال: وربا الجاهلية موضوع وأول رباً أصعُ رباناً ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله .

وجه الدلالة: كل ربا الجاهلية موضوع أبطله النبي ﷺ وأول ما أبطل من الربا ربا أقرابه .

الفرع الثاني

ربا الفضل تعريفه - حكمه

أولاً: تعريفه:

- **عند الحنفية:** زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي وهو الكيل أو الوزن أو الجنس .

- **وعند الشافعية:** زيادة أحد العوضين عن الآخر في بيع ربوي متحد الجنس .

- **وعند الحنابلة:** التاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه الربا .

فمما سبق: يتضح من خلاله أن معنى ربا الفضل هو الزيادة عند اتحاد الجنس فيما توافرت فيه علة الربا كبيع الذهب بالذهب متفاضلاً وبيع التمر بالتمر متفاضلاً .

ثانياً: حكم ربا الفضل:

- اتفق الفقهاء على تحريم ربا الفضل إذا اجتمع مع النسبة

- إذا انفرد فلهم في ذلك رأيان:

أنه حرام وهو مذهب جمهور الصحابة وكافة الفقهاء	مباح وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس .
1- عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" . 2- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ (لا تتبعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تتبعوا الورق بالورق إلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تتبعوا منها غائباً بناجز) . <u>وجه الدلالة:</u> بقوله: لا تشفوا: أي لا تفضلوا وقوله بناجز أي حال والمراد لا تتبعوا مؤجلاً بحال ويحتمل أن يراد به الغائب وهو أهم من المؤجل كالجائز عن المجلس مطلقاً مؤجلاً كان أو حالاً فالحديث واضح الدلالة في تحريم ربا الفضل لقوله ﷺ "فمن زاد أو استزاد فقد أربى" . 3- عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ استعمل رجل على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله ﷺ (أكل تمر خيبر هكذا؟) قال: لا والله يا رسول الله إنا لناخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بثلاثة . فقال رسول الله ﷺ: (لا تفعل بع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدرهم جنيباً) . <u>وجه الدلالة:</u> التمر الجنيب قيل: الطيب وقيل: الصلب فالحديث يدل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي سواء اتفقا في الجودة والرداءة أو اختلفا وأن الكل جنس واحد وأيضاً ما كان يوزن إذا بيع بجنسه مثل الكيل فلا يباع متفاضلاً وإن اختلفا في الجودة والرداءة بل يباع رديئة بالجنهات مثلاً ثم يشتري الجدي إذ لا فرق بين المكيل والموزون في الحكم .	<u>أولاً: القرآن الكريم:</u> (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) . <u>وجه الدلالة:</u> وأحل الله البيع يتناول بيع الدرهم بالدرهم نقداً وقوله وحرم الربا لا يتناوله لأن الربا عبارة عن الزيادة وليست كل زيادة محرمة بل قوله وحرم الربا إنما يتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى فيما بينهم بأنه ربا . وذلك هو ربا النسبة فكان قوله وحرم الربا مخصوصاً بالنسبة فثبت أن قوله وأحل الله البيع يتناول ربا النقض . <u>مناقشة هذا الدليل:</u> لا تُسلم أن لفظ الربا في الآية خاص بل عام أيضاً <u>ثانياً: السنة النبوية المطهرة:</u> 1- أن النبي ﷺ قال: "إنما الربا في النسبة" . وزاد مسلم في رواية عن ابن عباس قال: "لا ربا فيما كان يداً بيد" . 2- ما رواه عمرو بن دينار أنه سمع أبا المنهال يقول: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدرهم بينهما فضل فقلت: ما أرى هذا يصلح فقال: لقد بعته في السوق فما عاب ذلك على أحد . فأتيت البراء بن عازب فسألته قال: قدم النبي ﷺ المدينة وتجارنا هكذا فقال: "ما كان يداً بيد فلا بأس به وما كان نسبة فلا خير فيه" . 3- أبو المنهال قال: سألت زيد ابن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق ديناً" . <u>وجه الدلالة:</u> الأحاديث تدل على أنه لا ربا فيما كان يداً بيد وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين وصاع تمر بصاعين من التمر وكذا الحنطة وسائر الربويات . <u>مناقشة هذه الأدلة:</u> 1- تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد دلالاته بالمنطوق وكان ابن عباس يذهب إلى العمل بمفهوم حديث أسامة ثم رجع عنه . 2- وأجابوا عن حديث أسامة عدة إجابات منها: <u>أولاً:</u> أنه منسوخ وهذه إجابة ضعيفة . <u>ثانياً:</u> أن المراد: لا ربا الربا المغلط الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد . <u>وبهذا:</u> يتضح سلامة إجماع الفقهاء من المعارضة واتفاق كلمة الأمة على تحريم ربا الفضل في البيوع .

المطلب الثالث:

ما يجري فيه الربا

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن الأشياء التي يجري فيها الربا الأصناف الستة واستدلوا بحديث عبادة ابن الصامت (رضي الله عنه) أن الرسول ﷺ قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد".

ولكنهم اختلفوا فيما عدا هذه الأصناف وكان خلافهم على رأيين:

الجمهور يجري في هذه الأشياء الستة وما وافقها في العلة	مذهب أهل الظاهر لا يجري الربا فيما عدا الأشياء الستة المذكورة في الحديث
أولاً: القرآن الكريم: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا". وجه الدلالة: تدل الآية الكريمة على تحريم كل زيادة. ثانياً: السنة النبوية المطهرة: 1- نهى ﷺ عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل وجه الدلالة: الطعام اسم لما يؤكل عادة بوجه عام سواء . نوقش هذا الدليل: بأن هذا وإن كان عاماً فهو مخصوص ببيان النبي ﷺ في الأجناس الستة . الرد على هذه المناقشة: بيان بعض ما يتناوله العموم لا يكون تخصيصاً . 2- نص النبي ﷺ على البر وهو أعلى المطعومات وعلى الملح وهو أدنى المطعومات فكان ذلك تنبيهاً على أن ما بينهما لاحق بأحدهما لأنه ينص تارة على الأعلى لينبه به على الأدنى فإذا ورد النص على الأعلى والأدنى كان أوكد تنبيهاً على ما بينهما وأقوى شاهداً في لحوقه بأحدهما . 3- نهى رسول الله ﷺ عن المزابنة يبيع الرجل ثمر حائطه إن كان نخلاً بثمر كفاً وإن كان كرمًا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله . وجه الدلالة: الحديث أدخل نوعاً جديداً غير الستة المنصوص عليها وهو: الزبيب والعنب فدل ذلك على أن الربا لا يقتصر على تلك الأشياء الستة المنصوص عليها .	: "وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ". وجه الدلالة: بين لنا الرسول ﷺ الأصناف التي يجري فيها الربا من عدمه ف يجوز أن يكون شيء من الربا لم يبينه الرسول ﷺ ولو كان كذلك لكان الرسول ﷺ عاصياً لربه إذ أمره بالبيان فلم يبين وهذا لا يجوز . 2- "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا". وجه الدلالة: أن الله أحل البيع وبيّن الرسول ﷺ الأمور التي يجري فيها الربا فلا يجوز القياس عليها إذ ما عداها على أصل الإباحة ولأنه لا يجوز قياس غير المنصوص على المنصوص لإثبات الحكم .

سبب الخلاف: في أنه هل يقاس على الأصناف الستة غيرها مما شاركها في العلة أم لا؟ أم أن التحريم لأعيانها فقط ولا يقاس عليها غيرها؟

الرأي المختار: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تحريم ربا الفضل في الأصناف الستة وغيرها مما شاركها في العلة ولذلك لقوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة ولأن القياس دليل شرعي فيقاس على الأصناف الستة ما في معناها وتخصيص الأصناف الستة بالذكر أن عامة المعاملات يومئذ كان بها .

المطلب الرابع:

علة الربا

علة الربا هي وجوب المساواة التي يلزم عند فوتها الربا وفي فتح القدير أي علة تحريم الزيادة .

تحرير محل النزاع:

- 1- اتفق الفقهاء على جريان الربا في كل من الأصناف الستة التي نص عليها حديث عبادة
- 2- اتفق الفقهاء على جريان الربا في كل مطعوم مقتات خاضع للكيل أو الوزن وشذ الظاهرية .
- 3- اتفق الفقهاء على عدم جريان الربا فيما لم يكن مطعوماً ولم يخضع للكيل أو وزن ولم يتوفر فيه التجانس .
- 4- واختلفوا في جريان الربا في الأصناف الأخرى بناء على اختلافهم في العلة والتي هي مناط الحكم .

سبب الخلاف:

أ - الاختلاف في مبدأ تعليل النصوص حيث ذهب جماهير العلماء إلى أن الأصل في العبادات التوقيف وفي المعاملات التعليل .

- وذهب الظاهرية إلى التمسك بظواهر النصوص وعدم تعليقها وترتب على ذلك اختلاف في كثير من الفروع الفقهية ونها جريان الربا في غير الأصناف الستة الواردة في حديث عبادة ابن الصامت .

ب - الاختلاف في علة الربا والتي هي مناط الحكم لأن العلة غير منصوص عليها واستنبطها العلماء من النصوص استنباطاً بالاجتهاد والفقهاء مختلفون في اجتهادهم ولهذا اختلفوا في تحديد علة الربا تبعاً لاختلافهم في الاجتهاد والنظر .

وكان اختلاف الجمهور في علة الربا على عدة آراء أشهرها ما يلي:

الرأي الأول: للحنفية ورواية للحنابلة

1- أن يكون المال بما يوزن أو يكال .

2- أن يتخذ الجنس في المالين .

ومن ثم فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم وسواء كان ثمناً أو ثمنين فيجري الربا في الحنطة والشعير والملح والأذرة والعسل وهذه مطعمة ويجي في الذهب والفضة وهذه أثمان ويجري في الحديد والرصاص والجواهر وهي غير أثمان ولكنها موزونة ويجري في الحناء والجص مثلاً وهما يكالان .

وخلاصة القول: علة ربا الفضل هي الكيل أو الوزن مع وحدة الصنف وأما علة ربا النساء فهي وجود أحد الوصفين اتحاد الصنف في الكيل أو الوزن ويستثنى من ذلك الذهب والنحاس فيجوز بينهما النساء بالإجماع مثال ذلم بيع البر بالشعير فإتبعها مختلفان من حيث الصنف ولكنهما متقآن كيلاً فيجوز التفاضل بأن يباع مد بمدين ولكن يحرم النساء فلا يجوز تأخير التقابض .

واستدلوا بـ :- 1- القرآن الكريم: " أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ * وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ * وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ "

(وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ)

وجه الدلالة من الآيات: جعلت الآيات الكريمات حرمة الربا منوطاً بالمكيل والموزون مطلقاً عن شرط الطعم فدل ذلك على أن العلة هي الكيل أو الوزن . ومعنى أوفوا الكيل أي: أتموه ولا تكونوا من المخسرين .

ثانياً: السنة النبوية المطهرة:

1- قال رسول الله " لا تأخذوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين إني أخاف عليكم الربا " فقال رجل يا رسول الله: أرايت الرجل يبيع الفرس بأفراس والنخبة بالإبل: قال لا بأس بذلك إذا كان يداً بيد .

نوقش: بأن الاستدلال به لا يصح (ضعيف) .

2- أحاديث الباب كحديث عبادة رضي الله عنه وفيه: " البر بالبر " .

وجه الدلالة فيه: أن الحبة الواحدة لا يبيعها أحد ولو باعها لم يجز لأنها ليست بمال متقوم فعلم أن المراد البر الذي هو مال متقوم ولا نعلم ذلك إلا بالكيل فصارت صفة الكيل ثابتة بمقتضى النص .

- وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم : " مثلاً بمثل " . يشعر بأن كل موزون مع اتحاد نوعه يكون كذلك وكل مكيل كذلك .

3- جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : (من أين هذا؟) قال بلال: كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: (أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتريه) . وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بني عدي الأنصاري فاستعمل على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "أكل تمر خيبر هكذا؟" قال:

لا والله يارسول الله إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع فقال رول الله ﷺ: " لاتفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان".

وجه الدلالة: دل الحديثان على أن بيع الجنس بجنسه مع التفاضل في أحدهما يعد ربا .

نوقش: بأنه ﷺ أراد أن يحرم كل جنس مما يكال بشيء من جنسه متفاضلاً أو نسيئة .

ثالثاً: المعقول:

المعاملات في الإسلام تقوم على العدل وهو مقاربة التساوي أو التساوي في البديلين وذلك يحصل بالكيل أو الوزن حيث المماثلة في الصورة واتحاد الصنف يوجب المماثلة في المعنى وهذه هي العدالة في أوسع صورها دليل ذلك: قوله ﷺ كما مر في الحديث " .. مثلاً بمثل سواء بسواء".

الرأي الثاني: أن علة ربا الفضل في الذهب والفضة الثمنية مع اتحاد الصنف وأما علة في الأصناف الأربعة الباقية فهي الادخار والاقتنيات مع اتحاد الصنف .

وأما علة ربا النسيئة: فهي الطعم والادخار دون اعتبار للاقتنيات أو وحدة الصنف ويجوز ربا التفاضل في غير الأطعمة الربوية الواردة ففي حديث عبادة بن الصامت وما يقاس عليها .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1- أن النبي ﷺ نص في حديث عبادة على عدد من الأصناف فدل ذلك على أنه ﷺ قصد التنبيه بكل واحد منها على ما في معناه ولو كان الطعم وحده هو العلة لاكتفى الرسول ﷺ بالتنبيه على صنف واحد من هذه الأصناف الأربعة فلما ذلك عدداً منها علم أنه قصد بذلك التنبيه على المعنى الزائ على الطعم وهو الادخار والاقتنيات .

2- الذهب والفضة خلقا ثمينين ولهذا انعقد الاجماع على جواز اسلام الذهب والفضة فيما سواها من الأموال ولو كانت علة الربا في الذهب والفضة .

3- لما كان معقول المعنى في الربا إنما هو ألا يغبن بعض الناس بعضاً وأن تحفظ أموالهم فوجب أن يكون ذلك في أصول المعاش وهي الأقوات .

مناقشة أدلة المالكية:

1- أنه ينتقض بالحطب والإدام فإنه يستصلح بهما القوت ولا ربا فيهما .

2- إن ما أضافه متأخروا المالكية إلى ضابط العلة يعد تخبطاً وعدم استقامة على رأي واضح .

الرأي الثالث: علة ربا لافضل هي الثمنية في الذهب والفضة والطعم في الأصناف الأربعة الباقية مع اتحاد الصنف في كل منهما وعلة ربا النسيئة هي الثمنية في الذهب والفضة والطعم في الأربعة الباقية فقط .

واستدلوا على ذلك أولاً: السنة النبوية المطهرة:

رسول الله ﷺ يقول: "الطعام بالطعام مثلاً بمثل".

وجه الدلالة: الحكم علق باسم مشتق والقاعدة تنص على تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق والطعم هو المصدر الذي علق به الحكم .

ولأن الطعم وصف شرف والثمنية وصف شرف فيقتضي التعليق بهما .

ثانياً: القياس: تنص القاعدة على أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فإذا وجد الطعم وجدت حرمة الربا وإذا انتفت انتفى الحكم فالحب ما دام مطعوماً يجري فيه الربا فإذا زرع وخرج نباتاً بطل فيه الربا .

وأما دليلهم على أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية فهو نفس دليل المالكية .

وخلاصة ذلك: الذهب والفضة من العادن القيمة والثمنية فليست العلة أنهما من الموزونات بل كونهما من المعادن الثمينة المستعملة في قياس قيم الأموال .

الرأي الراجح: رأي الحنفية لأنه يرتبط بقاعدة العدالة والتي هي أساس التشريع كله ومن ذلك العدل في المعاملات والذي يعني التساوي أو مقاربة التساوي بين البديلين .

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على
سيدنا محمد وآله الطيبين
الطاهرين